COLENDA 8ª TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Apelação Criminal nº 5000553-66.2017.404.7000/PR
Relator: Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto
Apelantes: MARIANO MARCONDES FERRAZ
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PETROBRAS
Apelados: OS MESMOS

P A R E C E R

OPERAÇÃO LAVA JATO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃOATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA.
1. **PRELIMINARES**.
1.1 **Incompetência.** Não há que se falar em aplicação do artigo 88 do Código de Processo Penal, uma vez que, de acordo com a teoria da ubiquidade, **o julgamento do crime de lavagem de dinheiro**, conexo à prática de corrupção envolvendo o Diretor de Abastecimento da Petrobras, **não exige a aplicação extraterritorial da legislação penal brasileira.**
1.2 **Nulidade de provas**. As informações bancárias relacionadas às contas mantidas por Paulo Roberto Costa foram **transmitidas segundo todos os procedimentos previstos para a cooperação internacional**, conforme ampla documentação juntada aos autos, sendo que **nenhum dos réus questiona a exatidão das informações** retratadas nos documentos, tornando irrazoável a alegação de ausência de integridade e autenticidade das provas.
1.3 **Cerceamento de defesa**. O indeferimento de requerimento extemporâneo de **acesso a provas** sobre fatos de conhecimento do recorrente não representa cerceamento de defesa, sobretudo quando guarda mínima ou nula plausibilidade de comprovação da pretensão da defesa, tendo em vista o conjunto probatório.
2. **MÉRITO**.
2.1. **Apelação do réu Mariano Marcondes Ferraz**
2.1.1 **Crime de Corrupção Ativa. Há provas do pagamento de vantagens indevidas** realizado por MARIANO MARCONDES em benefício de PAULO ROBERTO COSTA, em razão do seu cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, **no interesse do contrato firmado com a empresa DECAL**, representada pelo recorrente. A corrupção ativa está configurada em razão das provas que mostram a **iniciativa de MARIANO em buscar lobistas/operadores** de confiança do então Diretor, a fim de estabelecer um **contato que pressupunha o pagamento de propina**. MARIANO MARCONDES **não era titular do interesse econômico** subjacente ao sucesso do empreendimento, a este se vinculando pela promessa de **recebimento de comissão ao angariar novos clientes**, o que se deu com a celebração do contrato com a PETROBRAS. **Não há elementos para reconhecer a ocorrência de exigência**, por parte de PAULO ROBERTO COSTA, e **tampouco plausibilidade em reconhecer em MARIANO MARCONDES a condição de vítima de coação**. O conflito entre **ganhar a remuneração, praticando uma ilegalidade, ou deixar de obter um ganho**

extra, agindo em conformidade com a ética republicana, não caracteriza situação de exculpação. A **continuidade dos pagamentos ao destinatário** da propina após sua saída do cargo estatal reforça o entendimento acerca do consenso entre os envolvidos, pois **demonstra credibilidade da palavra do agente** que prometeu a vantagem.

2.1.2 **Crime de Lavagem de Dinheiro.** O crime antecedente à lavagem de dinheiro é o crime de corrupção. O **objeto da corrupção ativa transforma-se no produto da corrupção passiva** com a transferência bancária realizada por MARIANO MARCONDES. A **transferência do valor se dá mediante mecanismo de ocultação da propriedade**, desenvolvido por PAULO ROBERTO COSTA, com o auxílio de HUMBERTO MESQUITA. Não há percurso necessário entre o crime de corrupção e lavagem, devendo ser **afastada a alegação de absorção** entre as condutas. Os fatos indicam que a **definição do pagamento da propina** mediante depósito em conta mantida por empresa *offshore* é **resultado do consenso** entre os envolvidos, para a conveniência de ambos. A circunstância de que **um dos oito depósitos** realizados pelo recorrente **originou-se de sua conta bancária pessoal** não enseja dúvidas acerca do seu dolo por se tratar de **evento isolado**, possivelmente decorrente de um **descuido** do recorrente. Eventual atendimento às normas bancárias de prevenção à lavagem de dinheiro **não afastam a ocorrência do crime, a despeito do *compliance*, se a ocultação ou dissimulação se consumam,** notadamente em ambiente bancário que revela **atendimento meramente formal a tal regramento**. O destinatário da propina que busca **pessoa de suas relações familiares**, para **instituir empresa *offshore* sem atividade econômica** e em seu nome abrir **conta bancária no exterior**, inegavelmente pratica conduta objetivamente direcionada à **ocultação da origem e da propriedade de valores**. O crime de lavagem se **consuma independentemente de completar-se o ciclo de reintegração dos valores** à economia formal. A **manutenção em depósito** bancário de valor de origem ilícita por um **lapso de tempo** também é uma **estratégia de ocultação** da origem dos valores. **Não há imputação de emissão de *invoices***, de modo que os documentos juntados aos autos constituem **meramente reforço probatório**, não podendo ser considerados fatos típicos praticados pelo recorrente.

2.1.3. **Dosimetria. Crime de corrupção ativa: Não há desproporcionalidade** na exasperação da pena base com base no **valor da propina,** dado acidental e variável no crime de corrupção, que atinge patamar significativo no presente caso, ainda que inferior a casos conexos da Operação Lava Jato. Não há possibilidade de reconhecer uma **culpabilidade** favorável. É possível que a **atenuação da pena com base na confissão seja inferior a 1/6**, se houver motivação para tanto, como no presente caso. **Crime de lavagem de dinheiro:** Os **atos de lavagem mediante utilização de *offshore*** merecem pena superior, sendo adequada a consideração do **valor das operações para dimensionar** as consequências do crime. Não há possibilidade de reconhecer uma **culpabilidade** favorável. É possível que a **atenuação da pena com base na confissão seja inferior a 1/6**, se houver motivação para tanto, como no presente caso. A confissão parcial **não autoriza a diminuição da pena** prevista no artigo 1º, §5° da Lei 9.613/98. Os atos de lavagem possuem autonomia a substancialidade que justificam a incidência, para cada um destes, do tipo penal, não sendo possível falar-se em crime único de lavagem. Em que pese ausente a demonstração matemática da proporcionalidade da **pena de multa,** foi ela aplicada abaixo do que autorizaria a pena privativa de liberdade aplicada.

2.1.4. **Indenização pelos danos mínimos e confisco.** O pagamento da propina foi realizado com os ganhos obtido pelo recorrente para a celebração do contrato, de modo que não há como se falar em dano mínimo à PETROBRAS. Deve ser mantido o confisco, todavia, incidente sobre o valor auferido por MARIANO MARCONDES com a prática do crime.

2.2. **Apelação da acusação.** A **culpabilidade** deve ser reconhecida como negativa. Não estão presentes elementos para justificar a incidência da **causa de aumento de pena** prevista no artigo 333, parágrafo único, do CP ou no artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98. A continuidade delitiva entre os atos de lavagem deve ser mantida em razão da unidade de desígnios que reúne a prática dos atos.
3. Parecer pelo p**rovimento em parte da apelação da acusação e provimento em parte da apelação do réu.**

SUMÁRIO DA MANIFESTAÇÃO

I - FATOS
II – FUNDAMENTOS
II.1 – PRELIMINARES
II.1.1 – Incompetência
II.1.2 – Nulidade de provas
II.1.3 – Cerceamento de Defesa
II.2 – MÉRITO
II.2.1 – Da apelação do réu MARIANO MARCONDES FERRAZ
II.2.1.1 – Do crime de corrupção passiva
II.2.1.2 – Do crime de lavagem de dinheiro
II.2.1.3 – Da dosimetria
II.2.2 – Da apelação da acusação
III – CONCLUSÃO

I – FATOS

Constam dos autos de apelações criminais interpostas pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** (e. 144)[1], pela assistente de acusação **PETROBRAS** (e. 159) e pelo réu **MARIANO MARCONDES FERRAZ** (e. 191) em face da sentença (e. 142), prolatada pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e publicada em 05/03/2018, que julgou procedente em parte a ação penal, nos seguintes termos:

[1] Eventos citados referem-se ao processo originário em primeira instância.

"213. Condeno Mariano Marcondes Ferraz:

a) por um crime de corrupção ativa, do art. 33 do CP; e

b) por oito crimes de lavagem de dinheiro, do art, 1º, V e do art. 1º, caput. da Lei n.º 9.613/1998, pelo repasse de produto de crime corrupção mediante condutas de ocultação e dissimulação."

As **penas do réu** foram assim estabelecidas:

– **MARIANO MARCONDES FERRAZ**: **10 anos e 04 meses de reclusão**, e **145 dias-multa**, no valor de **5 salários mínimos**;

Determinou-se, ainda, na sentença, o seguinte:

"216. Em decorrência da condenação pelo crime de lavagem, decreto, com base no art. 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, a interdição de Mariano Marcondes Ferraz, para o exercício de cargo ou função pública ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade.

217. O período em que o condenado ficou preso deve ser computado para fins de detração da pena (item 23).

218. No processo 5054168-05.2016.4.04.7000, a pedido do MPF, foi decretada a prisão preventiva de Mariano Marcondes (decisão de 26/10/2016, evento 4 daqueles autos).

219. Em audiência de 03/11/2016 (termo no evento 32 do processo 5054168-05.2016.4.04.7000), a prisão foi substituída pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) proibição de ausentar-se do país, com manutenção dos passaportes acautelados em Juízo;

b) fiança de três milhões de reais;

c) proibição de mudar-se de endereço sem autorização do Juízo; e

d) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo.

220. A fiança foi devidamente depositada (evento 34 do processo 5054168-05.2016.4.04.7000).

221. Ficam mantidas as cautelares substitutivas, sem a necessidade de imposição da prisão na fase de eventual apelação.

222. Considerando o montante da vantagem indevida repassada por Mariano Marcondes Ferraz a Paulo Roberto Costa, decreto, com base no art. 91, II, "b", do CP, o confisco do valor prestado de fiança até o valor equivalente em reais do montante pago de vantagem indevida, USD 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50).

223. Os valores confiscados serão revertidos à vitima, a Petrobrás, pois em função de contratos com ela celebrados é que o condenado repassou propinas a Paulo Roberto Costa.

224. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo no equivalente em reais do montante da vantagem indevida, USD 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50), o valor mínimo necessário para indenização dos danos decorrentes dos crimes. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde então até o pagamento e agregado de juros de 0,5% ao mês.

225. O valores reverterão à Petrobrás, vítima.

226. O confisco compensará o valor da indenização, devendo ser pago eventual saldo."

As imputações da denúncia foram assim sintetizadas no relatório da sentença:

"3. Em síntese, segundo a denúncia, no âmbito das investigações da assim denominada Operação Lavajato, foram colhidas provas de que empresas fornecedoras da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás pagariam, de forma sistemática, vantagem indevida a dirigentes da estatal.

4. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para

também corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

5. Aos agentes políticos cabia dar sustentação à nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

6. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

7. A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes do esquema criminoso da Petrobras.

8. Em nova síntese, Mariano Marcondes Ferraz, representante da Decal Brasil Ltda, teria pago vantagem indevida no valor de USD 868.450,00 ao então Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com a finalidade de obter a renovação do contrato de prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios de granéis líquidos em instalações portuárias localizadas no Porto de Suape/PE.

9. O primeiro contrato firmado entre a Decal do Brasil e a Petrobras data de 25 de outubro de 2006, com aditivos em 15/01/2008 e 30/04/2009, e permaneceu vigente até 30/04/2012 (anexo3).

10. O segundo contrato firmado entre as partes, com idêntico objeto, data de 01 de maio de 2012 e tinha prazo de validade de cinco anos (anexo4).

11. Segundo consta da peça acusatória, a vantagem indevida teria sido paga por meio de oito transferências bancárias efetuadas por Mariano Marcondes Ferraz, pessoa física, e por intermédio de suas off-shores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp, as quais totalizaram USD 870.000,00, entre as datas de 19/05/2011 a 21/02/2014, em favor da conta em nome da off-shoe OST Invest & Finance Inc, mantida no Banco Lombard Odier, sediado em Genebra, Suíça, cujo procurador e titular era Humberto Sampaio Mesquita e cujo beneficiário final era Paulo Roberto Costa.

12. Enquadrou o MPF os fatos nos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro."

Diante da sentença foram interpostas as seguintes apelações.

Apelações da acusação e da assistente de acusação

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** interpôs da apelação (e. 144). Nas razões recursais (e. 157), postula: 1) a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade negativa; 2) a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 333, parágrafo único do Código Penal, tendo em vista a atuação de PAULO ROBERTO COSTA na agilidade da renovação do contrato, com o propósito de receber a propina; 3) a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 1°, § 4° da Lei 9.613/98, em razão da realização de 8 depósitos ao longo do prazo de três anos, mediante mecanismo sofisticado, o que revelaria profissionalismo criminoso e 4) contra o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de lavagem, porquanto o uso de três *off-shores*, ao longo de três anos, não permitiria a conclusão de circunstâncias semelhantes, exigidas pelo artigo 71 do Código Penal.

A **PETROBRÁS**, na condição de assistente de acusação, ratificou a apelação apresentada pelo Ministério Público Federal (e. 159).

Apelação do réu MARIANO MARCONDES FERRAZ.

O réu **MARIANO MARCONDES FERRAZ** interpôs apelação (e. 142), apresentando razões recursais na segunda instância (e. 6 no TRF4).

Em **preliminar**, o apelante sustenta: **1)** incompetência para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro praticado no exterior, tendo em vista a incidência do artigo 88 do CPP e do artigo 2°, II da Lei 9.613/98, fixando-se a competência no Rio de Janeiro, em razão da especialidade destas normas na delimitação da jurisdição, de modo a afastar a conexão e a prevenção da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR; **2)** nulidade das provas produzidas a partir do pen drive mencionado no Relatório de Análise SPEA/PGR n° 15/2015, tendo em vista a ausência de integridade e autenticidade da prova nele constante, causada pela quebra da cadeia de custódia; **3)**

cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de juntada da íntegra das mensagens eletrônicas obtidas na caixa de correio funcional de PAULO ROBERTO COSTA, cuja relevância com o tema debatido demonstrou-se com a juntada nas alegações finais apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – de forma extemporânea, como reconhecido na sentença - de cópia de uma das mensagens enviadas pelo então Diretor de Abastecimento sobre o contrato firmado entre PETROBRAS e DECAL.

No **mérito**, em relação ao *crime de corrupção passiva,* o réu argumenta, inicialmente, **1)** que o contrato firmado é lícito, sem origem na atuação de qualquer grupo cartelizado e tampouco obtido mediante o pagamento de propina, tendo sido firmado com garantia de vantagens econômicas à PETROBRAS. Alega, ainda, **2)** que os pagamentos – cuja ocorrência não nega – não decorrem de oferta ou promessa de entrega dos valores e tampouco tinham por objetivo determinar que PAULO ROBERTO COSTA praticasse ou omitisse ato de ofício. Sustenta que os pagamentos tiveram como objetivo evitar que a renovação do contrato entre DECAL e PETROBRAS fosse obstaculizada pela conduta de PAULO ROBERTO COSTA, o que acabaria por causar a falência da empresa, dada a sua dependência total do contrato com a PETROBRAS.

Nesse sentido, salienta que buscou iniciar as negociações com a PETROBRAS para a renovação do contrato em 2010, mas que PAULO ROBERTO COSTA somente agiu neste sentido em setembro de 2011, quatro meses após o primeiro depósito realizado em sua *off-shore*. Ao longo das negociações, o preço pretendido pela empresa representada pelo recorrente foi diminuído em 28%, o prazo contratual reduzido à metade, sendo que, no total, o processo de renegociação e renovação contratual durou 2 anos, evidenciando que não houve favorecimento ou agilização do processo de contratação.

Ademais, afirma **3)** que o custo da propina saiu de sua remuneração de representação da empresa DECAL, de modo que não representou qualquer envolvimento dos proprietários/administradores da empresa, e tampouco prejuízo à PETROBRAS.

Tais elementos, na sua avaliação, **4)** demonstram que o recorrente foi vítima do crime de concussão, praticado por PAULO ROBERTO COSTA, o que é corroborado pelo depoimento de FERNANDO (BAIANO) SOARES, relatando possíveis retaliações àqueles que

deixassem de honrar pagamentos de propina, bem como, pelos registros apreendidos com o genro de PAULO ROBERTO COSTA, evidenciando que os depósitos tinham que ser cobrados, o que demonstraria terem se realizado de modo involuntário, sob ameaça.

Assim, ataca os argumentos apresentados na sentença, afirmando **5)** que a continuidade dos pagamentos após a saída de PAULO ROBERTO COSTA da Diretoria de Abastecimento comprova o receio de que sua conduta pudesse inviabilizar o contrato, notadamente através da influência sobre outros funcionários na PETROBRAS – justamente o contrário do que conclui a sentença – e que a exigência de que MARIANO MARCONDES tivesse buscado as autoridades para revelar o crime, sob pena de ser considerado corruptor, é um atentado ao princípio da presunção de inocência, que não leva em consideração as reais condições de funcionamento do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, requer **6)** o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta de acordo com o direito, na medida em que, caso tivesse deixado de pagar os valores a PAULO ROBERTO COSTA, a empresa DECAL poderia vir a falir, já que não haveria outros operadores no mercado de petróleo para alugar a área de tancagem.

Em relação ao *crime de lavagem de dinheiro*, afirma **1)** que os argumentos apresentados na sentença, padronizados para a Operação Lava Jato, não se aplicam ao presente caso, em razão de sua singularidade, em que não é possível apontar a ilicitude do dinheiro utilizado para o pagamento de propina, oriundo da comissão do recorrente para concluir o negócio; **2)** de modo que, ausente a origem ilícita dos valores e por não ser possível falar em crime antecedente, não se configura a lavagem, que só poderia ser caracterizada no máximo a partir do recebimento dos valores por PAULO ROBERTO COSTA, através de HUMBERTO MESQUITA.

3) Que a condenação por lavagem em relação ao pagamento da propina viola a proibição do *ne bis in idem*, porquanto não há autonomia ou independência material que distinga os fatos imputados como corrupção ou lavagem, na medida em que o pagamento da propina constitui mera conclusão do delito de corrupção; **4)** e que não há, objetivamente, atos de

ocultação/dissimulação, inicialmente, porque MARIANO MARCONDES residia na Suíça, portanto não utilizava contas "no exterior", ademais, porque os beneficiários e agentes das contas bancárias estavam corretamente identificados perante as respectivas instituições financeiras, em conformidade com a legislação suíça aplicável, e porque a utilização de empresas *off-shore* não é, de antemão, ilícita. Nesse último ponto, esclarece que as contas por ele gerenciadas estão vinculadas a atividades lícitas na área de *trading*, de modo que não se pode falar em desvirtuamento de suas finalidades jurídico-econômicas.

5) Aponta ausência de dolo, demonstrada na realização de transferência de sua conta pessoal, bem como ausência de participação sua relevante para o ato de lavagem praticado por PAULO ROBERTO COSTA, na medida em que não tinha poder sobre a definição do "local de pagamento" da propina exigida. **6)** Salienta ainda que não haveria integração ao sistema econômico legítimo dos valores "lavados", porquanto seriam apenas "mantidos" pelo seu destinatário, PAULO ROBERTO COSTA, de modo que sequer se poderia imputar a este último o crime de lavagem.

7) Sob outro prisma, sustenta que, além de não terem sido citadas na denúncia, as 8 notas fiscais simuladas relacionadas aos depósitos foram produzidas ingenuamente pelo recorrente, em uma única ocasião, posteriormente aos fatos, com a eclosão da Lava Jato, após demanda feita pelo gerente do banco onde HUMBERTO MESQUITA mantinha a conta recebedora dos recursos; **8)** mas que tal comportamento somente poderia ser caracterizado como auto-encobrimento impunível, resultante da pretensão de omitir um delito em que se envolvera; **9)** e ainda assim, mediante um meio inidôneo, porquanto caberia ao prestador dos serviços, e não o recorrente, suposto contratante, emiti-las.

Quanto à **dosimetria**, o apelante sustenta, em relação à fixação da pena base do *crime de corrupção ativa*, **1)** a impossibilidade de incremento da pena em razão do valor da propina, a título de circunstâncias do crime, pois o valor é substancialmente inferior a outros casos julgados na Operação Lava Jato, de modo que não justificaria o incremento de 6 meses na pena; **2)** a necessidade de reconhecer uma culpabilidade favorável, que justifique a atenuação da pena, tendo em vista as circunstâncias que levaram-no a praticar o delito; **3)** ser indevida a diminuição da pena em apenas 3 meses, pelo reconhecimento da confissão parcial, tendo em vista o teor da Súmula 545

STJ, sendo irrelevante a discordância quanto a sua ilicitude, bem como sustenta **4)** ser inaplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 317, §1° do CP.

Em relação ao *crime de lavagem de dinheiro*, sustenta, **5)** a inexistência de especial sofisticação nos atos de lavagem de dinheiro, sobretudo em consideração às observações feitas sobre as reais condições da prática dos atos imputados a título de lavagem, devendo ser afastada a desqualificação da vetorial circunstâncias; **6)** que o valor das operações financeiras não justificam, concretamente, a desqualificação da vetorial consequências; que as duas vetoriais não justificariam o incremento de 1 ano e 6 meses da pena, notadamente se comparada a outros casos julgados na Operação Lava Jato; **7)** a necessidade de reconhecer uma culpabilidade favorável, que justifique a atenuação da pena, tendo em vista as circunstâncias que levaram-no a praticar o delito; **8)** ser indevida a diminuição da pena em apenas 3 meses, pelo reconhecimento da confissão parcial, tendo em vista o teor da Súmula 545 STJ, sendo irrelevante a discordância quanto a sua ilicitude, bem como sustenta **9)** ser aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 1º, §5° da Lei 9.613/98, em razão de sua colaboração com as investigações; **10)** deve ser afastada a caracterização da prática de 8 crimes de lavagem, em continuidade delitiva, porquanto se trata de crime único, vinculado a um único crime de concussão praticado por PAULO ROBERTO COSTA.

Quanto à **pena de multa**, afirma que não houve fundamentação para a definição do número de dias-multa.

Em relação ao **valor da reparação mínima dos danos**, sustenta, inicialmente, que não há qualquer demonstração do prejuízo à PETROBRAS, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mesmos sentido, no tocante ao **confisco** do valor dado em fiança, sustenta que não há que se falar em produto ou proveito auferido com o crime, de modo que não houve fundamentação para a decisão.

Contrarrazões foram apresentadas à apelação da acusação e da assistente de acusação pela defesa de MARIANO MARCONDES FERRAZ (e. 162).

Após a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a apresentação de razões recursais, foi aberta vista a esta Procuradoria Regional da República da 4ª Região para parecer.

Em síntese: *Data dos fatos: entre maio de 2011 e fevereiro de 2014 (corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro); Denúncia recebida em 02/03/2017; Sentença condenatória publicada em 05/03/2018.*

II – FUNDAMENTOS

Introdução

A investigação sobre os fatos, objeto da Operação Lava Jato, começou na Representação Criminal n° 2006.7000.018662-8 – posteriormente tombada como IPL n° 714/2009 quando, no final de 2008 e em 2009, surgiram informações de que Alberto Youssef estaria operando financeiramente para grupos envolvidos com corrupção no governo federal, através da empresa CSA Project Finance, com vistas à implantação de uma unidade fabril em Londrina/PR da empresa Dunel Indústria e Comércio, o que caracterizaria lavagem de dinheiro praticada no Estado do Paraná.

Além de uma série de informações concretas, foram apresentados diversos comprovantes de depósito e recibos de pagamento de valores compatíveis com os números citados na notícia de crime, notadamente pagamentos realizados para Ferramentas Gerais Ltda. pelas empresas Angel Serviços Terceirizados e Torre Comércio de Alimentos, no valor de quase R$275.000,00. Confirmada por diligências preliminares a verossimilhança das informações originais, prestadas por Hermes Magnus, bem como diante de outros elementos de prova, a Autoridade Policial formulou pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal das empresas Dunel, Torre Comércio, Angel Serviços, J N Rent a Car e CSA Project Finance. Através desta medida, e com base em Relatórios Financeiros do COAF, verificou-se expressiva movimentação financeira na empresa CSA Project Finance, bem como a recorrência de transações envolvendo a empresa MO Consultoria, cujo sigilo fiscal e bancário também restou afastado.

As provas indicaram que as empresas Angel Serviços Terceirizados e Torre Comércio de Alimentos estavam sob o controle do doleiro Carlos Habib Chater, e que os pagamentos relatados no início da investigação efetivamente caracterizavam-se como lavagem de dinheiro, tendo por objeto propinas pagas ao ex-deputado federal José Janene (Ação Penal n° 5047229-77.2014.404.7000).

A atuação de Carlos Habib Chater não se limitava a essa operação, pois realizava expressiva movimentação financeira. No curso da interceptação telefônica deferida (Autos n° 5026387-13.2013.404.7000), a sua rede de conexões começou a ser delineada, revelando-se estruturas paralelas de doleiros, justificando o desmembramento das investigações (IPL 1000/2013 – 5048401-88.2013.404.7000, direcionado às atividades da doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama e IPL 1002/2013 – 5048550-84.2013.404.7000, direcionado às atividades do doleiro Ricardo Henrique Srour).

Igualmente, os elementos colhidos nas investigações indicaram a consistente atuação de Alberto Youssef em atividades financeiras suspeitas, desmembrando-se as investigações contra ele no IPL 1041/2013 – 5049557-14.2013.404.7000.

O aprofundamento das investigações mostrou, inclusive, que a empresa MO Consultoria, do laranja Waldomiro de Oliveira, foi usada para realizar transferências financeiras ilegais, suportadas por falsos contratos, firmados com a Sanko Sider (em benefício do Consórcio CNCC), Galvão Engenharia, OAS e outras grandes construtoras. Ademais, a oitiva de Waldomiro de Oliveira revelou que a empresa era efetivamente gerenciada por Alberto Youssef.

A interceptação das comunicações de Alberto Youssef (Autos n° 5027775-48.2013.404.7000) demonstrou seus diálogos com Márcio Bonilho, sócio da empresa Sanko Sider, indicando que os valores por ela repassados para a empresa MO Consultoria decorriam de propina relacionada com as obras feitas pelo Consórcio liderado pela empresa Camargo Corrêa na implantação da Refinaria Abreu e Lima para a Petrobrás.

Identificou-se, ainda, nos e-mails interceptados, a aquisição por Alberto Youssef de um veículo Land Rover Evoque para Paulo Roberto Costa, ex-Diretor de Abastecimento

da Petrobras, no valor de R$ 250.000,00 (Autos n° 5049597-93.2013.404.7000 – evento 54, PET 01, p. 16-19), o que, junto com outros indícios, levou à realização de buscas e apreensões nos endereços do ex-Diretor, onde foram reunidos elementos que apontavam para um grande esquema de corrupção.

Com os elementos reunidos, foram ajuizadas, dentre outras, a Ação Penal n° 5026212-82.2014.404.7000, contra Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e outros, a Ação Penal n° 5025699-17.2014.404.7000 contra Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e outros, e foram retomadas antigas ações penais suspensas pelo acordo de delação premiada firmada por Alberto Youssef por ocasião das investigações no Banestado.

Igualmente, foram ajuizadas ações penais contra os grupos de doleiros relacionados à atuação de Carlos Habib Chater (Autos n° 5026663-10.2014.404.7000), Raul Srour (Autos n° 5025692-25.2014.404.7000) e Nelma Penaso Kodama (Autos n° 5026243-05.2014.404.7000).

O forte conjunto probatório reunido e transformado em imputações de graves crimes motivou alguns dos envolvidos a buscarem a realização de acordos com o Ministério Público Federal para usufruírem os benefícios da colaboração premiada, mediante apresentação de provas sobre a organização criminosa que era objeto das investigações.

Nesse sentido, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Julio Gerin de Almeida Camargo, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef revelaram a atuação conjunta e coordenada sobre contratos da Petrobras de grupos de políticos, grandes empreiteiras e funcionários públicos, que se ajustaram para drenar recursos públicos. Mediante contratos superfaturados, obtidos com a prática de cartel e fraude a licitações, grandes somas de recursos (que atingem a casa dos bilhões de reais) foram incorporadas ao patrimônio das empresas, utilizadas para o pagamento de propina aos funcionários públicos e repassadas para políticos, partidos políticos diversos. A operação das transações financeiras contava com a participação de empresas de fachada, de laranjas e doleiros, com vista à lavagem de dinheiro e ao envio de recursos ao exterior.

A partir de novas linhas de atuação, foram ajuizadas ações penais contra executivos das empreiteiras OAS (Autos n° 5083376-05.2014.404.7000), Galvão Engenharia (Autos n° 5083360-51.2014.404.7000), Engevix (Autos n° 5083351-89.2014.404.7000), Mendes Jr (Autos n° 5083401-18.2014.404.7000), Camargo Corrêa e UTC (Autos n° 5083258-29.2014.404.7000), o que motivou a realização de novas colaborações premiadas, como dos executivos Dalton Avancini, Ricardo Pessoa e Gerson de Mello Almada.

As investigações sobre a atuação de políticos relacionados às atividades ilícitas encontram-se nos foros definidos pela Constituição Federal, notadamente perante o Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da tramitação de ações penais já ajuizadas contra ex-deputados federais, como Pedro Corrêa, Luiz Argolo e André Vargas (Autos n° 5023121-47.2015.404.7000 e 5023135-31.2015.404.7000).

Denúncia

Nesse feito, em breve síntese, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra MARIANO MARCONDES FERRAZ, afirmando que, no ano de 2011, ofereceu vantagem indevida a PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, no montante de quase US$ 870 mil, com o propósito de obter a renovação do contrato de tancagem nas instalações da empresa DECAL, no porto de SUAPE - Pernambuco.

Na qualidade de representante da empresa DACAL DO BRASIL, MARIANO MARCONDES procurou PAULO ROBERTO COSTA com o propósito de obter a renovação contratual do ajuste celebrado em abril de 2009 e que se encerraria em abril de 2012. Buscando aproximar-se do então Diretor de Abastecimento, solicitou a FERNANDO (BAIANO) SOARES que os aproximasse, o que se realizou num jantar. Segundo a denúncia, MARIANO MARCONDES ofereceu a propina com o propósito de dar seguimento ao processo de contratação, afastar obstáculos e efetivar a contratação desejada.

O valor da propina – US$868.450 – foi pago a partir da conta pessoal de MARIANO MARCONDES e das contas bancárias das suas empresas TIK TRADING, FIRMA INVEST e FIRMA PART, mediante 8 depósitos em conta em nome da *off-shore* OST INVEST &

FINANCE, da qual HUMBERTO MESQUITA, genro de PAULO ROBERTO COSTA, era controlador e o beneficiário econômico final.

Tendo em vista as características destas transações bancárias, imputa a denúncia a ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização dos valores pagos indevidamente, mediante depósito dos valores em contas de titularidade de *offshore* controlada pelo genro de PAULO ROBERTO COSTA, HUMBERTO MESQUITA.

II.1 – PRELIMINARES

II.1.1 – Incompetência

MARIANO MARCONDES sustenta a incompetência para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro, porquanto praticado no exterior, atraindo a incidência do artigo 88 do CPP e do artigo 2°, II da Lei 9.613/98 e fixando a competência no Rio de Janeiro, em razão da especialidade destas normas na delimitação da jurisdição, de modo a afastar a conexão e a prevenção da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, deve-se reconhecer a ausência de formulação do questionamento à competência territorial mediante apresentação da exceção de incompetência, tornando inoportuno o questionamento apresentado a partir das alegações finais, como concluiu a sentença proferida (evento 134 SENT1 itens 25 a 37).

De todo modo, a alegação de incidência do artigo 88 do Código de Processo Penal, que regula a competência territorial nos casos de extraterritorialidade da lei penal (art. 7° do CP), não deve ser provida, sobretudo, por que ausente a condição básica de sua aplicação, ou seja, de crime cometido no exterior.

O lugar do crime é definido segundo a **teoria da ubiquidade**, adotada no

Código Penal:

> "Art. 6º Considera-se praticado o crime **no lugar em que ocorreu a ação** ou omissão, no todo ou em parte, bem como **onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado**."

O artigo 6° do Código Penal delimita o lugar do crime, para fins de fixação da jurisdição criminal brasileira, como o lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Embora não se repute correta a análise exclusiva da competência voltada unicamente para o crime de lavagem, devendo ser considerado, igualmente, o crime de corrupção, estes parâmetros legais para a definição do lugar do crime devem se aplicar sobre a lavagem de dinheiro imputada a MARIANO MARCONDES.

Para delimitar a territorialidade da jurisdição criminal brasileira, não basta a menção ao local do resultado do crime. Ao cingir suas observações apenas às transações financeiras, que inequivocamente se realizaram no território Suíço, o recorrente elimina as considerações sobre o lugar onde praticadas as ações que culminaram neste resultado.

De acordo com o que se depreende da denúncia apresentada, MARIANO MARCONDES, em concurso de agentes com HUMBERTO MESQUITA e PAULO ROBERTO COSTA, agiram a fim de ocultar a transferência e a propriedade de valores oriundos do crime de corrupção. O delito de lavagem de dinheiro por eles praticado se desenvolve por um conjunto de ações, que se inicia a partir do acordo mútuo de realizar os depósitos em conta *offshore* mantida pelo genro de PAULO ROBERTO COSTA.

Segundo o depoimento prestado por FERNANDO (BAIANO) SOARES, MARIANO MARCONDES foi apresentado a PAULO ROBERTO COSTA em reunião realizada no apartamento do recorrente, em jantar promovido exclusivamente para que tal aproximação ocorresse (evento 99 TERMO2 dos autos originários):

> Ministério Público Federal:- Gostaria de saber por que o Mariano te convidou pra esse jantar?

> Fernando Antônio Falcão Soares:- Não, na verdade, o Mariano me procurou, falando sobre um contrato de uma das empresas que ele ou era sócio ou representava que tinha um contrato de tancagem, de arrendamento de tancagens com a Petrobrás. E que esse contrato estava próximo de chegar ao fim, e ele queria ver a possibilidade de renovar esse contrato e melhorar as condições, os valores que estava sendo cobrados nesse contrato. E ele perguntou se eu poderia ajudar. Eu disse a ele que eu ia conversar com o Paulo, e inclusive ver a possibilidade de marcar um encontro, eu, ele e Paulo pra tratarmos do assunto. conversei com o Paulo, o Paulo disse que conhecia o assunto, conhecia o contrato, e s**e disponibilizou a gente fazer esse encontro com o Mariano. (inaudível) Ele combinou um jantar na residência dele e eu fui com o Paulo nesse jantar.**

Trata-se de relato que lança frontal contradição ao relato de MARIANO MARCONDES, de que residia no exterior e, portanto, de lá teria determinado a realização dos depósitos. Pelo contrário, MARIANO MARCONDES confirma em seu interrogatório a ocorrência do jantar por ele organizado, em seu apartamento, para reunir-se com o lobista FERNANDO (BAIANO) SOARES e com PAULO ROBERTO COSTA, para discutir o contrato da DECAL.

O recorrente se escora em documento emitido pela Suíça (evento 6 END6), reconhecendo sua residência no exterior. Todavia, ainda que MARIANO MARCONDES possuísse residência na Suíça, isto não demonstra que lá permanecesse durante todo o tempo ou mesmo que de lá houvesse ajustado a prática da lavagem ou de lé determinado a realização das transferências financeiras. O documento apresentado pela defesa apenas comprova que MARIANO fixou residência legal na Suíça, possivelmente para fins fiscais, como aludiu em seu interrogatório.

MARIANO MARCONDES, na qualidade de representante de empresas europeias com contratos na PETROBRAS, ainda que pudesse passar parte de seu tempo naquele continente, também se fazia presente no Brasil, de modo a atender os interesses daquelas companhias. Não por outro motivo, agendou jantar em sua casa no Rio de Janeiro, para receber PAULO ROBERTO COSTA e, em seguida, com ele se reuniu nos escritórios da PETROBRAS.

É relativamente irrelevante se MARIANO MARCONDES deu a ordem de realização das oito transferências bancárias enquanto estava na Suíça, na medida em que o acerto prévio com PAULO ROBERTO COSTA, ato integrante da imputação da conduta de lavagem,

ocorreu em território brasileiro. Nessa linha, os contornos do crime indicados pela prova permitem concluir que tanto MARIANO MARCONDES como PAULO ROBERTO COSTA agiram no Brasil para desencadear as ações de lavagem de dinheiro, cujos resultados produziram-se no exterior.

Por tal razão, não há que se falar em aplicação do princípio da extraterritorialidade para justificar a jurisdição criminal brasileira, porquanto o crime não foi cometido totalmente no estrangeiro, nos termos do artigo 7° do Código Penal. **O mais adequado é reconhecer o lugar do crime como duplo: no Brasil e no exterior, e reputar ausentes razões para invocar o artigo 88 do Código de Processo Penal.**

Nada obstante, apenas deve-se salientar que o eventual reconhecimento da possibilidade de aplicação extraterritorial da lei penal, seja por força de tratados e convenções internacionais que estabelecem os princípios de cooperação entre os Estados para o julgamento dos crimes de corrupção e lavagem (*artigo 4º da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais - Decreto n° 3.678/2000; artigo 42 e 43 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção - Decreto n° 5.687/2006*), seja por força do artigo 7°, I, b) do Código Penal, como decidido pelo STJ[2], não afasta o reconhecimento da conexão dos crimes imputados ao recorrente com a Operação Lava Jato.

Trata-se de mais um caso de corrupção envolvendo um Diretor da Petrobras, verificando-se nítida conexão probatória com as denúncias já apresentadas e provas reunidas no âmbito da investigação da Operação Lava Jato, nos termos reconhecidos por este TRF da 4ª Região, pelo STJ e STF.

O fato de não estar presente na corrupção imputada ao recorrente a atuação do cartel de empreiteiras não significa que se trata de um caso isolado que deva ser extirpado do âmbito da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Como já se viu, a corrupção envolvendo a Diretoria Internacional da PETROBRAS também não tinha o Clube de empreiteiras no exercício da corrupção ativa, mas nem por isso deixou-se de reconhecer a conexão probatória (ACR's 5061578-51.2015.4.04.7000, 5051606-23.2016.4.04.7000, 5039475-50.2015.4.04.7000, dentre outras).

[2] RHC 201700196290, Felix Fischer, STJ - Quinta Turma, DJE Data: 12/06/2017.

Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, o artigo 2º, II da Lei 9.613/98 não determina o julgamento separado do crime antecedente e do ato de lavagem, apenas permite que esse último seja processado de modo independente. Caso ambas as infrações possam ser levadas a juízo concomitantemente, não há qualquer impedimento. Nesse caso, nota-se ainda que se proporciona ao acusado maior garantia para o exercício da ampla defesa.

Assim, o interesse na colheita de provas e de unidade de julgamento impõe o reconhecimento da conexão, devendo ser afastadas as alegações de incompetência.

II.1.2 – Nulidade de provas

O réu sustenta nulidade das provas produzidas a partir do *pen drive* mencionado no Relatório de Análise SPEA/PGR n° 15/2015, tendo em vista a ausência de integridade e autenticidade da prova nele constante, causada pela quebra da cadeia de custódia.

Não é correta a afirmativa do apelante.

De acordo com os esclarecimentos apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (evento 128 ALEGFINAIS1 dos autos originários), foram juntados aos autos a decisão da quebra de sigilo bancário da conta, os documentos pertinentes à obtenção dos documentos da conta mediante cooperação jurídica internacional e os documentos da própria conta, como extratos etc (evento 38 *idem*).

De modo a comprovar a licitude da obtenção das informações, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL juntou os seguintes documentos (evento 60 *idem*): a) pedido de quebra de sigilo bancário de contas no exterior de PAULO ROBERTO COSTA (ANEXO3); b) decisão judicial que deferiu a medida cautelar (ANEXO4); c) pedido de cooperação jurídica internacional – COOPIN FTLJ 01/2014) (ANEXO5); d) Ofício nº 825/2015, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) com a resposta ao pedido de cooperação pela autoridade suíça (ANEXO6); e e) a integralidade dos documentos enviados relativos à conta OST Invest & Finance Inc. (ANEXOS 7 ao 14).

Deve-se ressaltar que a regularidade do procedimento foi devidamente demonstrada através do Ofício nº 825/2015, do DRCI, o qual serviu para informar que a Autoridade Central suíça restituiu regularmente o pedido, diligenciado e cumprido, culminando com o envio do dispositivo USB contendo as informações bancárias especificadas na documentação que instruiu o pedido.

Ainda assim, o órgão ministerial descreveu detalhadamente todo o processo de internalização dos dados bancários e juntou aos autos o ofício pelo qual o DRCI encaminhou o pedido de cooperação jurídica às autoridades suíças (evento 113 PET1 e ANEXO3 *idem*).

Apenas para reforçar brevemente o quanto já exposto, os dados bancários foram obtidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL durante viagem oficial das autoridades brasileiras à cidade de Lausanne, na Suíça, em novembro de 2014. Naquele momento já havia sido afastado judicialmente o sigilo bancário de PAULO ROBERTO COSTA e o próprio colaborador havia firmado autorização de acesso aos dados no interesse das investigações realizadas na Operação Lava Jato.

Antes da recepção do dispositivo pela autoridade central, somente foram analisadas as informações com vistas organizar os registros e a assegurar a integridade e a veracidade das declarações prestadas pelo colaborador. Em expressão utilizada no âmbito de cooperações jurídicas internacionais, naquele momento os dados foram recebidos “informalmente”, hipótese em que o envio é destinado a fins de inteligência ou para a antecipação de provas nos casos de urgência.

Posteriormente, os mesmos dados bancários foram remetidos ao Brasil dentro dos ditames legais que regem o procedimento e com base na solicitação formal feita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, como se vê do ofício encaminhado pela autoridade brasileira e da resposta recebida das autoridades suíças.

Dessa forma, a utilização dos dados bancários em instrumentos apuratórios ou em autos judiciais ocorreu somente após o envio das informações pelas autoridades suíças, isto

é, as informações qualificaram-se como meios probatórios apenas depois do encaminhamento pelas autoridades centrais de ambos os países.

Nesse sentido, a internalização dos arquivos depositados na mídia USB obedeceu aos preceitos legais e ao procedimento de cooperação jurídica internacional consoante o tratado bilateral celebrado entre Brasil e Suíça, não havendo irregularidade na custódia das informações e tampouco no uso dos dados com finalidade probatória.

Por fim, perde toda a razoabilidade o questionamento quanto à integridade ou veracidade das informações bancárias que comprovam os depósitos feitos na conta da *offshore* mantida pelo genro de PAULO ROBERTO COSTA, diante da uníssona concordância por todas as partes envolvidas, inclusive o recorrente, quanto à efetiva ocorrência dos fatos nelas retratados.

Por tais razões, não é plausível se falar em nulidade da prova.

II.1.3 – Cerceamento de Defesa

MARIANO MARCONDES sustenta cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de juntada da íntegra das mensagens eletrônicas obtidas na caixa de correio funcional de PAULO ROBERTO COSTA, cuja relevância com o tema debatido demonstrou-se com a juntada nas alegações finais apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – de forma extemporânea, como reconhecido na sentença – de cópia de uma das mensagens enviadas pelo então Diretor de Abastecimento sobre o contrato firmado entre PETROBRAS e DECAL.

Sem razão o apelante.

O recorrente alega que as mensagens constantes na caixa de correio eletrônico de PAULO ROBERTO COSTA poderiam conter alguma comprovação de que o ex-Diretor da PETROBRAS estaria exigindo a propina paga pelo recorrente, o que confirmaria a sua principal tese de defesa, ou seja, que seria vítima do crime de concussão e não autor do crime de corrupção ativa. Assim, afirma que há possibilidade que exista algum indício, por exemplo, da

postura de PAULO ROBERTO COSTA em bloquear a contratação da DECAL, de modo a pressionar o pagamento da propina.

A hipótese apresentada, entretanto, carece de razoabilidade, uma vez contraposta às demais provas produzidas nos autos, que indicam a iniciativa de MARIANO MARCONDES em oferecer o pagamento de propina, a fim de garantir a contratação da DECAL pela PETROBRAS.

Ademais, é sintomático que o recorrente somente tenha buscado esta prova a partir da juntada (extemporânea) pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de uma e-mail relativamente insignificante, enviado pelo próprio recorrente para PAULO ROBERTO COSTA (evento 128 ANEXO2 dos autos originários).

Como se trata de uma mensagem enviada por MARIANO MARCONDES, é evidente que não lhe cabe afirmar que a desconhecia. Ademais, em seu interrogatório, o recorrente chaga a fazer menção à sua iniciativa de pleitear à PETROBRAS a renovação do contrato que se encerraria em 2012, tal como consta na mensagem de e-mail juntada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na fase de alegações finais (evento 119 TERMO1):

> Juiz Federal:- Mas depois teve uma outra renovação em 2012, é isso?
>
> Mariano Marcondes Ferraz:- Aí teve uma renovação em 2012 e aí foi feito um contrato de 5 anos.
>
> Juiz Federal:- E aí quando que surgiu essa questão dos pagamentos ao Paulo Costa?
>
> Mariano Marcondes Ferraz:- Os pagamentos começaram, quer dizer, mesmo ao longo do contrato, nós sempre fomos pleiteando aumento de contrato, quer dizer, não necessariamente quando termina o contrato você pleiteia um aumento de contrato. Mesmo durante o contrato, durante o... Não me lembro se foi o primeiro, mas logo no início da conversa com eles, a idéia era fazer um contrato de 10 anos. Então, ao longo do contrato, sempre houveram reclamações da minha parte com relação à tarifa e com relação a prazo. Então, enfim, aí surge a história com o diretor Paulo Roberto.

Por se tratar de documento representativo de fato envolvendo o próprio recorrente, a sua juntada extemporânea não consiste, propriamente, em novidade. Por isso, caso a

defesa do recorrente realmente reputasse plausível a identificação de alguma prova da prática de concussão por parte de PAULO ROBERTO COSTA no conjunto de seus *email's*, deveria ter formulado, ao longo da ação penal, requerimento para a apresentação de cópia das mensagens, ou a submissão destes textos a filtros de pesquisa, caso a sua totalidade não pudesse ser disponibilizada à defesa, a fim de evidenciar eventual mensagem relacionada ao tema.

Todavia, o que se vislumbra é a exploração de uma circunstância processual, decorrente de uma postura da acusação reputada inadequada pelo juízo *a quo*, que o recorrente busca transformar em suposto cerceamento de defesa. De fato, ao perceber o equívoco na juntada do documento pelo órgão acusatório, o recorrente identificou uma oportunidade para formular requerimento probatório de baixa plausibilidade, após o encerramento da instrução criminal. Com o previsível indeferimento do pedido, estariam lançadas as bases para a alegação de cerceamento de defesa.

Mas esta não ocorre, devendo se imputar unicamente ao próprio recorrente sua inércia em pleitear a realização da prova no momento adequado. A narrativa da situação pelo recorrente leva à falsa impressão de que há mensagens de conhecimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, mas que não teriam sido juntadas apenas para inviabilizar o exercício da defesa. Todavia, não há notícias de mensagens no sentido apontado pela defesa. E mais, conforme será demonstrado a seguir, a existência de mensagens de PAULO ROBERTO COSTA que evidenciem a concussão é dissonante do contexto em que se deu a oferta/aceitação de propina.

Assim, não se vê cerceamento de defesa ao apelante.

Com estas considerações, reputa improcedentes as alegações preliminares apresentadas.

II.2 – MÉRITO

II.2.1 – Da apelação do réu MARIANO MARCONDES FERRAZ

De acordo com a denúncia, MARIANO MARCONDES, na qualidade de representante da empresa DECAL, titular de concessão para exploração de Terminal de Tancagem no porto de SUAPE, ofereceu, a título de vantagem indevida decorrente da renovação do contrato de tancagem com a PETROBRAS, a quantia de quase US$870 mil ao então Diretor de Abastecimento, PAULO ROBERTO COSTA.

O valor foi submetido a atos de ocultação de propriedade, sendo imputada a prática de atos de lavagem de dinheiro.

Em suma, o réu **MARIANO MARCONDES FERRAZ** foi **condenado** pela prática dos crimes previstos no **art. 333 do CP** – corrupção ativa , pena de 3 anos e 3 meses de reclusão e 45 dias-multa –, no **art. 1º, *caput*, da Lei 9.613/98** – lavagem de ativos por 8 vezes, pena de 7 anos e 1 mês e 100 dias-multa, na forma do **art. 69 do CP,** totalizando pena de **10 anos e 4 meses de reclusão** e de **145 dias-multa**, no valor de **5 salários mínimos**.

II.2.1.1 – Do crime de corrupção ativa

Síntese das alegações do apelante

No mérito o réu argumenta que o contrato firmado é lícito, sem origem na atuação de qualquer grupo cartelizado e tampouco obtido mediante o pagamento de propina, tendo sido firmado com garantia de vantagens econômicas à PETROBRAS. Alega, ainda, que os pagamentos – cuja ocorrência não nega – não decorrem de oferta ou promessa de entrega dos valores e tampouco tinham por objetivo determinar que PAULO ROBERTO COSTA praticasse ou omitisse ato de ofício.

Sustenta que os pagamentos tiveram como objetivo evitar que a renovação do contrato entre DECAL e PETROBRAS fosse obstaculizada pela conduta de PAULO ROBERTO COSTA, o que acabaria por causar a falência da empresa, dada a sua dependência total do contrato

com a PETROBRAS. Nesse sentido, salienta que buscou iniciar as negociações com a PETROBRAS para a renovação do contrato em 2010, mas que PAULO ROBERTO COSTA somente agiu neste sentido em setembro de 2011, quatro meses após o primeiro depósito realizado em sua *off-shore*.

Ao longo das negociações, o preço pretendido pela empresa representada pelo recorrente foi diminuído em 28%, o prazo contratual reduzido à metade, sendo que, no total, o processo de renegociação e renovação contratual durou 2 anos, evidenciando que não houve favorecimento ou agilização do processo de contratação. Ademais, afirma que o custo da propina saiu de sua remuneração de representação da empresa DECAL, de modo que não representou qualquer envolvimento dos proprietários/administradores da empresa, e tampouco prejuízo à PETROBRAS.

Tais elementos, na sua avaliação, demonstram que o recorrente foi vítima do crime de concussão, praticado por PAULO ROBERTO COSTA, o que é corroborado pelo depoimento de FERNANDO (BAIANO) SOARES, relatando possíveis retaliações àqueles que deixassem de honrar pagamentos de propina, bem como, pelos registros apreendidos com o genro de PAULO ROBERTO COSTA, evidenciando que os depósitos tinham que ser cobrados, o que demonstraria terem se realizado de modo involuntário, sob ameaça.

Assim, ataca os argumentos apresentados na sentença, afirmando que a continuidade dos pagamentos após a saída de PAULO ROBERTO COSTA da Diretoria de Abastecimento comprova o receio de que sua conduta pudesse inviabilizar o contrato, notadamente através da influência sobre outros funcionários na PETROBRAS – justamente o contrário do que conclui a sentença – e que a exigência de que MARIANO MARCONDES tivesse buscado as autoridades para revelar o crime, sob pena de ser considerado corruptor, é um atentado ao princípio da presunção de inocência, que não leva em consideração as reais condições de funcionamento do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta de acordo com o direito, na medida em que, caso tivesse deixado de

pagar os valores a PAULO ROBERTO COSTA, a empresa DECAL poderia vir a falir, já que não haveria outros operadores no mercado de petróleo para alugar a área de tancagem.

Não assiste razão ao apelante.

Restando inequívoco o pagamento de vantagem indevida a PAULO ROBERTO COSTA, em razão da contratação da DECAL pela PETROBRAS, fatos que o recorrente não nega, sua defesa busca as circunstâncias da ocorrência deste pagamento, a fim de demonstrar que teria ocorrido o crime de concussão e não uma corrupção bilateral, ou seja, um acordo entre oferecer/aceitar, solicitar/prometer.

Nessa linha, faz alusão à ausência de favorecimento econômico à empresa DECAL no contrato firmado, à situação financeira vivenciada pela sua dependência do contrato a ser firmado com a PETROBRAS e ao longo tempo de negociação para a celebração do contrato, ressaltando que a continuidade do pagamento após a saída de PAULO ROBERTO COSTA da PETROBRAS comprovaria o temor infligido pelo Diretor de Abastecimento.

Entretanto, o que se observa é que a defesa busca algumas circunstâncias objetivas para comprovar a sua tese, buscando elidir a narrativa que evidencia a efetiva ocorrência de corrupção, ativa e passiva, resultante do comum acordo atingido por MARIANO MARCONDES e PAULO ROBERTO COSTA.

Inicialmente, deve-se compreender **a posição de MARIANO MARCONDES em relação à empresa DECAL**, titular da concessão da planta de armazenamento de combustíveis no porto de SUAPE, construída a partir das expectativas econômicas decorrentes da política de quebra do monopólio da PETROBRAS.

De acordo com a testemunha Jorge de Oliveira, administrador da DECAL BRASIL, MARIANO ocupava uma posição importante na estrutura da filial nacional da empresa, pois, embora titular de parte diminuta (5%) do capital social, compunha o seu Conselho de Administração. A ele cabia **conduzir as negociações comerciais para o desenvolvimento de**

novos clientes, cujo sucesso representava uma remuneração adicional para o recorrente (evento 99 TERMO3 dos autos originários):

> Ministério Público Federal:- E qual é o papel dele lá na empresa, quais são as funções dele?
>
> Jorge de Oliveira Lemos:- Ele é o vice presidente do conselho e no caso de negociações de maior peso ele fazia a parte comercial da empresa.
>
> (...)
>
> Defesa:- Esclarecimento, senhor Lemos, na época dessas renovações 2011 em diante, o **senhor Mariano Marcondes Ferraz, ele que realizou essas negociações, ele tinha alguma remuneração por realizar essas negociações ou** ele fez isso só na condição de sócio ou representante da Decal, o senhor pode me esclarecer?
>
> Jorge de Oliveira Lemos:- Posso. **Ele tem, ele tinha uma remuneração pra desenvolvimento de clientes ou pra angariamento de clientes**.
>
> Juiz Federal:- E o senhor pode me dizer mais ou menos quanto que era ou que bases que isso era definido?
>
> Jorge de Oliveira Lemos:- Mais ou menos isso girava em torno de, no inicio em torno de 2 milhões e meio ano, a 3 milhões de reais ano. E depois isso veio aumentando um pouco, porque também entraram alguns outros serviços que não eram só armazenagem.
>
> Juiz Federal:- Ele era sócio da Decal ou não?
>
> Jorge de Oliveira Lemos:- Sim, a firma, na realidade a empresa dele é a sócia.
>
> Juiz Federal:- Ah, sei. E havia algum contrato de representação, havia alguma formalização?
>
> Jorge de Oliveira Lemos:- Sim, existia sim.
>
> Juiz Federal:- O que era isso, era um bônus por novos negócios que ele recebia?
>
> Jorge de Oliveira Lemos:- **Era um bônus pra trazer clientes.** E como eu comentei, esse aluguel da tancagem toda por um prazo maior, na realidade, nos tirou de uma situação financeira que estava começando a ficar complicada, visto que até 2010 nós não tínhamos pago ainda o investimento feito. Então nós estávamos ainda no prejuízo, não conseguimos enviar ainda nem juro sobre capital próprio, nem dividendos aos acionistas, por conta de restrição do Banco Central. Então, só a partir de 2010, na verdade 2011, é que nós começamos

a ficar positivos na nossa contabilidade. Então, esse contrato, na realidade, com a Petrobras veio a nos ajudar nesse angariamento, digamos assim, de receitas.

Juiz Federal:- Quanto que ele recebeu por conta de bônus, por conta dessa renovação?

Jorge de Oliveira Lemos:- Nessa renovação ainda era nessa faixa de 3 milhões, de 3 milhões e alguma coisa. Ela veio aumentando, como eu disse, ela veio aumentando ao longo desses anos, ao longo do contrato, porque também entraram outros serviços que não estavam previstos lá no início dele.

Diante de um tímido início de operação comercial, a DECAL buscava, através da atuação de MARIANO MARCONDES, incrementar a utilização de sua infraestrutura logística, de modo a gerar receitas suficientes para remunerar os investimentos realizados pelos sócios estrangeiros.

MARIANO MARCONDES apresenta uma inverossímil narrativa, em que teria buscado uma reunião na sede da PETROBRAS com PAULO ROBERTO COSTA, em que teria notado o seu "desinteresse" pelo contrato em questão. Em seguida, após um jantar de confraternização e exposição da situação da empresa, teria ocorrido a **exigência** de propina.

Todavia, FERNANDO (BAIANO) FALCÃO é quem realmente esclarece qual foi **a estratégia adotada por MARIANO MARCONDES visando a obter o desejado contrato** com a PETROBRAS (evento 99 TERMO2 dos autos originários):

Ministério Público Federal:- Senhor Fernando, **o senhor conhece o senhor Mariano** Marcondes Ferraz?

Fernando Antônio Falcão Soares:- Sim, conheço.

Ministério Público Federal:- Em **quais circunstancias o senhor o conheceu?**

Fernando Antônio Falcão Soares:- Eu **fui apresentado ao Mariano,** se eu não me engano, no final de 2006, segundo semestre de 2006 **pelo Jorge Luz.**

Ministério Público Federal:- Que tipo de assunto era tratado nessa apresentação, o que aconteceu?

Fernando Antônio Falcão Soares:- **O Jorge me apresentou o Mariano como sendo**

> **uma pessoa que tinha vários assuntos, vários negócios junto à Petrobrás. E como eu tinha uma relação com o Paulo Roberto, se em algum momento ele precisasse de alguma coisa que eu pudesse ajudar a ele, ele poderia conversar comigo.** Foi esse o contexto do encontro, foi esse o contexto.
>
> (…)
>
> Fernando Antônio Falcão Soares:- Não, na verdade, **o Mariano me procurou, falando sobre um contrato de uma das empresas que ele ou era sócio ou representava que tinha um contrato de tancagem, de arrendamento de tancagens com a Petrobrás.** E que esse contrato estava próximo de chegar ao fim, e ele queria ver a possibilidade de renovar esse contrato e melhorar as condições, os valores que estava sendo cobrados nesse contrato. E ele perguntou se eu poderia ajudar. Eu disse a ele que eu ia conversar com o Paulo, e inclusive ver a possibilidade de marcar um encontro, eu, ele e Paulo pra tratarmos do assunto. conversei com o Paulo, o Paulo disse que conhecia o assunto, conhecia o contrato, e se disponibilizou a gente fazer esse encontro com o Mariano. (inaudível) Ele combinou um jantar na residência dele e eu fui com o Paulo nesse jantar.

MARIANO MARCONDES, em busca da recompensa prometida pela DECAL em decorrência da celebração de um contrato que daria total utilização à estrutura de armazenagem de combustíveis, **busca JORGE LUZ, o mais antigo dos lobistas/operadores em atuação da PETROBRAS. Este, por sua vez, o apresenta ao representante da nova geração de lobistas, FERNANDO (BAIANO) SOARES.**

MARIANO MARCODES, ao recorrer ao contato com tais operadores/lobistas, **demonstra inequívoco interesse em se envolver com seus métodos de atuação na PETROBRAS, que envolvem, entre outras coisas, pagamentos de comissão aos seus funcionários, sobretudo mediante transações financeiras envolvendo empresas *offshore*.**

Uma vez estabelecido o contato para se aproximar de PAULO ROBERTO COSTA, MARIANO MARCONDES faz a movimentação precisa para demonstrar ao então Diretor de Abastecimento que estava disposto a integrar um método já conhecido pelo mercado para selar contratos na PETROBRAS, o pagamento de propina ao Diretor. Organiza um jantar para que FERNANDO SOARES leve PAULO ROBERTO COSTA ao seu contato.

FERNANDO SOARES põe em termos muito claros, o que significa o fato de MARIANO MARCONDES ter buscado um lobista de confiança de PAULO ROBERTO COSTA, a fim de discutir o contrato com a PETROBRAS (evento 99 TERMO2 dos autos originários):

> Fernando Antônio Falcão Soares:- Eu acho que **todas as pessoas que tinham negócios com a Petrobras, e se eu vou, se eu me coloco a disposição pra resolver a questão de um contrato e eu levo um diretor comigo, que é o responsável pra esse contrato, no mínimo alguma coisa esse diretor está ganhando com isso. Ou é dinheiro ou é apoio político, alguma coisa o diretor está ganhando com isso.** Ele não foi simplesmente lá, porque ele queria comer bem, não foi isso. Então, eu acho que há um entendimento, um subentendimento do que está acontecendo.

Assim MARIANO MARCONDES produz o jantar em sua casa, com a presença dos três interessados, o lobista (FERNANDO SOARES), o contratante (PETROBRAS – PAULO ROBERTO COSTA) e a contratada (DECAL – MARIANO MARCONDES). Não se trata, como esclarece FERNANDO SOARES, de uma noite de amenidades e de boa comida, mas de um s**inal evidente, para todos os envolvidos, que a discussão de contrato a ser celebrado com a PETROBRAS envolveria o pagamento de vantagens indevidas.**

FERNANDO SOARES afirma, inclusive, que MARIANO MARCONDES já teria combinado com si acerca do pagamento de algum valor, a ser definido após a conclusão das negociações (evento 99 TERMO2 dos autos originários):

> Juiz Federal:- Em algum momento foi falado com o senhor sobre comissão ou propina relativamente a esse contrato?
>
> Fernando Antônio Falcão Soares:- Eu conversei com o Mariano sobre a comissão. Que eu cuidaria de ajudar na renovação, mas que eu cobraria uma comissão por isso.

Os sujeitos reunidos nesse jantar não são neófitos, que inocente ou ingenuamente, buscam dar um natural andamento para eventos econômicos que estão sob seu controle. **São pessoas que lidam com negociações de contratos já há alguns anos e que optaram**

por obter ganhos pessoais, através do emprego das vantagens indevidas, sempre denominadas por comissão.

De fato, PAULO ROBERTO COSTA já possuía dezenas de anos na PETROBRAS e desde 2003 ocupava a Diretoria de Abastecimento, a partir suspeitosa articulação do ex-deputado federal JOSÉ JANENE.

FERNANDO SOARES, por sua vez, operava exclusivamente na intermediação entre executivos de empresas e Diretores e gerentes da PETROBRAS, de onde retirava sua remuneração, com o desempenho de papel ativo na distribuição de propina para as contas *offshore* mantidas direta ou indiretamente pelos seus destinatários.

E **MARIANO MARCONDES, decidido a adotar os meios que fossem necessários, decide aderir ao pagamento de propina, o que lhe garantiria a bonificação prometida pela empresa DECAL**, em razão do angariamento de um contrato importante.

A partir do inequívoco sinal enviado pelo recorrente, ou seja, a realização de um jantar com FERNANDO SOARES, cuja presença indicava a PAULO ROBERTO COSTA que ali havia alguém disposto a corromper, tem-se o desdobramento do ato de corrupção, relatada pelo próprio réu (evento 99 TERMO1 dos autos originários):

> Juiz Federal:- E onde que foi essa solicitação?
>
> Mariano Marcondes Ferraz:- Se eu não me engano, foi lá mesmo no escritório dele lá na Petrobrás.
>
> Juiz Federal:- Antes ou depois do jantar?
>
> Mariano Marcondes Ferraz:- Imagino que seja depois do jantar, **porque primeiro houve o jantar, o Fernando apresentou, eu tive oportunidade de apresentar o negócio. No jantar não foi discutido questões de pagamento, foi a oportunidade de descrever o negócio e a aflição que nós tínhamos, como Decal, de um negócio que não era rentável para a empresa**.
>
> Juiz Federal:- E quando ele solicitou isso estava o senhor e ele ou estava mais gente?
>
> Mariano Marcondes Ferraz:- Não, sempre participei das reuniões com o Paulo Roberto sozinho, sempre eram reuniões normalmente feitas lá no próprio prédio da Avenida Chile.

Juiz Federal:- E o senhor se recorda mais ou menos os termos que ele colocou para o senhor, as palavras que ele utilizou?

Mariano Marcondes Ferraz:- Me colocou que **"para a coisa caminhar, era necessário fazer um pagamento". Ele foi direto ao assunto e o valor mencionado foi 3%.**

Juiz Federal:- Isso foi antes dessa renovação de 2012?

Mariano Marcondes Ferraz:- Foi antes da renovação, sim.

Ao contrário do que afirma o recorrente, **a frase singela e objetiva a ele dirigida por PAULO ROBERTO COSTA é a expressão verbal necessária para dar concretude a um arranjo bilateral,** envolvendo oferecimento/aceitação - solicitação/promessa, que foi iniciado por um passo dado por MARIANO MARCONDES, ao buscar JORGE LUZ e depois, FERNANDO SOARES para se aproximar do Diretor de Abastecimento.

Não se trata, portanto, de uma postura de exigência, tipificada no artigo 316 do Código Penal, como sustenta MARIANO MARCONDES.

As circunstâncias dos fatos em julgamento não evidenciam uma atitude de "sabotagem" pelo Diretor de Abastecimento, inclusive porque as instalações de tancagem já vinham sendo utilizadas de modo precário pela PETROBRAS. Denotam **um encontro de vontades, de interesses e de meios**. Por corresponder muito mais a um "início de conversa", dirigida por PAULO ROBERTO COSTA a quem já indicara estar disposto ao esquema, não se concretiza a exigência.

Já sob o **prisma pessoal** do recorrente, **não é possível reconhecer no recorrente a condição de vítima, ou seja a sujeição à suposta coação** que estaria sendo dirigida por PAULO ROBERTO COSTA.

MARIANO MARCONDES, **não é o principal interessado no desfecho econômico da empresa DECAL**. Embora titular de 5 % do capital social da sua filial *nacional*, **o que realmente vincula economicamente MARIANO MARCONDES à celebração do contrato com a PETROBRAS é o recebimento de sua comissão pela conclusão do negócio.** Como se viu nos depoimentos, ao recorrente foi prometido um ganho, uma remuneração, decorrente

exclusivamente da celebração do contrato. Ou seja, para o recorrente, a celebração do contrato com a PETROBRAS não significa o fracasso do empreendimento, mas o recebimento de valores.

Admitindo-se como verdadeira a narrativa acerca da situação financeira da empresa DECAL, que não se via capaz de enviar para a sua matriz uma remuneração condizente com as expectativas do investimento, percebe-se que **eventual "dificuldade financeira" que ensejaria a alegada "coação", incidiria nos membros da família Triboldi.**

MARIANO MARCODES afirma não ter dado conhecimento à família sobre a coação a ele dirigida. Simplesmente decidiu pagar de sua própria remuneração. Não há imputação ou provas do envolvimento direto dos membros do controle da empresa DECAL.

Portanto, MARIANO MARCONDES não é titular do interesse econômico envolvido na suposta asfixia financeira, operacional ou regulamentar da empresa DECAL, resultando **incongruente a sua alegação de vítima de algum tipo de coação**.

O recorrente estava numa **situação em que apenas poderia ganhar ou deixar de ganhar**. E nesse dilema, optou em ganhar, empregando os meios descritos na denúncia e pelos quais foi corretamente condenado por corrupção ativa.

Esta **não é, certamente, uma situação que admita o reconhecimento da inexigibilidade de conduta em conformidade com o direito**. Diante de uma promessa de ganhos para angariar um contrato de peso para a empresa DECAL, MARIANO MARCONDES não se via em perigo, em situação onde exigir-lhe agir em conformidade com o direito significaria desconsiderar (o julgador) a anormalidade das circunstâncias concretas que se apresentavam ao agente criminoso.

Não há qualquer anormalidade na situação econômica vivenciada pela empresa DECAL, e muito menos, na situação de MARIANO MARCONDES. A empresa decidiu investir num negócio portuário e está sujeita à dinâmica do mercado, que pode lhe garantir demanda e remuneração ou ociosidade e prejuízo. Já MARIANO MARCONDES está unicamente diante da oportunidade de fechar um negócio e receber sua comissão.

Nesse sentido, não há como argumentar que MARIANO MARCONDES estaria vivenciando um conflito de deveres, onde se veria entre evitar o pagamento de propina a um funcionário público ou evitar o insucesso econômico de um empreendimento. Não, na perspectiva de MARIANO MARCONDES, **o pagamento de propina a um funcionário público lhe garantiria um bônus e o não pagamento apenas lhe privaria de um ganho adicional**, que apenas lhe deixaria um pouco menos rico. Tais circunstâncias afastam qualquer consideração sobre incidência de causas supralegais de exculpação.

Por fim, uma breve consideração sobre **a continuidade dos pagamentos após a saída de PAULO ROBERTO COSTA da PETROBRAS**, que a sentença reputa indício da ocorrência da corrupção, ao passo que o recorrente sustenta representar indício da concussão.

Sobre a ocorrência, a única certeza que se possui está nas anotações feitas por HUMBERTO MESQUITA, narrando contatos de cobrança dos valores acertados. HUMERTO MESQUITA faleceu, PAULO ROBERTO COSTA afirma pouco se lembrar dos fatos, enquanto MARIANO MARCONDES, naturalmente, tende a afirmar que ali residiriam as provas de sua inocência.

Qual seria, afinal, a justificativa para a continuidade dos pagamentos feitos por MARIANO MARCONDES após a saída de PAULO ROBERTO COSTA da PETROBRAS?

Apesar das referências feitas no interrogatório do recorrente à continuidade da influência de PAULO ROBERTO COSTA na PETROBRAS, o que lhe permitiria interferir nas decisões sobre o contrato em vigor, trata-se de hipótese que está em desconformidade com as demais provas dos autos, que apontam que a propina foi paga exclusivamente ao Diretor de Abastecimento, sem a distribuição de valores às gerências a ele subordinadas. Nesse sentido, vislumbrar que PAULO ROBERTO COSTA iria se imiscuir, após a sua saída, sobre a gestão de um contrato menor no porto de SUAPE, de modo a expôr-lhe a questionamentos sobre o seu interesse em fazê-lo, não soa plausível.

Ao que tudo indica, e considerando o que se observou em ações conexas da Operação Lava Jato, em que diversas empreiteiras deram continuidade ao pagamento de vantagens indevidas, tanto a PAULO ROBERTO COSTA como a RENATO DUQUE, **trata-se de demonstrar ao mercado (da corrupção) a lealdade do agente às suas promessas, de modo a ser considerado um negociador confiável, permitindo futuros acertos que se baseiam, sobretudo, na palavra dos agentes envolvidos.**

Ou seja, MARIANO MARCONDES deu continuidade aos pagamentos porque **estava em jogo a sua credibilidade como representante comercial que promete vantagens indevidas**. Embora aguardasse as cobranças de HUMBERTO MESQUITA, já que sempre poderia contar com o esquecimento ou desinteresse de PAULO ROBERTO COSTA em receber (eram tantas fontes!), **uma vez concretizada a cobrança, MARIANO MARCONDES honrava sua palavra e depositava os valores anteriormente prometidos**.

Por tais razões, deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção ativa.

II.2.1.2 – Do crime de lavagem de dinheiro

Em relação ao *crime de lavagem de dinheiro*, MARIANO MARCONDES afirma que os argumentos apresentados na sentença, padronizados para a Operação Lava Jato, não se aplicam ao presente caso, em razão de sua singularidade, em que não é possível apontar a ilicitude do dinheiro utilizado para o pagamento de propina, oriundo da comissão do recorrente para concluir o negócio; de modo que, ausente a origem ilícita dos valores e por não ser possível falar em crime antecedente, não se configura a lavagem, que só poderia ser caracterizada no máximo a partir do recebimento dos valores por PAULO ROBERTO COSTA, através de HUMBERTO MESQUITA.

Sustenta que a condenação por lavagem em relação ao pagamento da propina viola a proibição do *ne bis in idem*, porquanto não há autonomia ou independência material

que distinga os fatos imputados como corrupção ou lavagem, na medida em que o pagamento da propina constitui mera conclusão do delito de corrupção; e que não há, objetivamente, atos de ocultação/dissimulação, inicialmente, porque MARIANO MARCONDES residia na Suíça, portanto não utilizava contas "no exterior", ademais, porque os beneficiários e agentes das contas bancárias estavam corretamente identificados perante as respectivas instituições financeiras, em conformidade com a legislação suíça aplicável, e porque a utilização de empresas *off-shore* não é, de antemão, ilícita. Nesse último ponto, esclarece que as contas por ele gerenciadas estão vinculadas a atividades lícitas na área de *trading*, de modo que não se pode falar em desvirtuamento de suas finalidades jurídico-econômicas.

Aponta ausência de dolo, demonstrada na realização de transferência de sua conta pessoal, bem como ausência de participação sua relevante para o ato de lavagem praticado por PAULO ROBERTO COSTA, na medida em que não tinha poder sobre a definição do "local de pagamento" da propina exigida. Salienta ainda que não haveria integração dos valores "lavados" ao sistema econômico legítimo, porquanto seriam apenas "mantidos" pelo seu destinatário, PAULO ROBERTO COSTA, de modo que sequer se poderia imputar a este último o crime de lavagem.

Sob outro prisma, sustenta que, além de não terem sido citadas na denúncia, as 8 notas fiscais simuladas relacionadas aos depósitos foram produzidas ingenuamente pelo recorrente, em uma única ocasião, posteriormente aos fatos, com a eclosão da Lava Jato, após demanda feita pelo gerente do banco onde HUMBERTO MESQUITA mantinha a conta recebedora dos recursos; mas que tal comportamento somente poderia ser caracterizado como auto-encobrimento impunível, resultante da pretensão de omitir um delito em que se envolvera; e ainda assim, mediante um meio inidôneo, porquanto caberia ao prestador dos serviços, e não o recorrente, suposto contratante, emiti-las.

Não assiste razão ao apelante.

O crime antecedente de corrupção, aquele que gera o objeto da lavagem, consiste **na celebração de um ajuste dúplice envolvendo solicitação/oferecimento de vantagem** indevida. Este evento, do qual tomou parte MARIANO MARCONDES, tem por objeto a promessa de pagamento e a correspondente obtenção de um contrato com a PETROBRAS.

O valor a ser utilizado para o pagamento da propina, enquanto permanece no patrimônio do corruptor, efetivamente não pode ser considerado "proveniente do crime". Ele tem origem nas demais atividades do agente e ainda **está em vias de se transformar em objeto da corrupção ativa e produto do crime de corrupção passiva. No momento da transferência bancária para** HUMBERTO MESQUITA, na perspectiva deste, **o valor é inequivocamente produto do crime de corrupção.**

Uma vez **gerado este produto do crime de corrupção**, com a mera disponibilidade financeira através da transferência bancária, **vislumbra-se, concomitantemente, a sua inserção na estrutura de ocultação da propriedade desenvolvida** por PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO MESQUITA, que passam a manter o recurso depositado de modo suficientemente afastado da sua fonte ilícita.

MARIANO MARCONDES sob distintas formas **adere e contribui para a efetividade desta estratégia de ocultação da origem e da propriedade**. Ao providenciar o depósito na conta *offshore* de HUMBERTO MESQUITA; ao utilizar, com exceção de uma ocorrência, outra *offshore* como fonte da transferência dos recursos.

Ou seja, **a discussão quanto à proveniência lícita dos recursos transferidos por MARIANO MARCONDES é irrelevante**, na medida em que se constata conduta sua que **contribui para a realização da lavagem por parte daquele que tem o controle sobre o produto do crime antecedente.**

A manutenção, por HUMBERTO MESQUITA, sob o comando de PAULO ROBERTO COSTA, da estrutura da *offshore* OST INVEST de modo dissimulado, ou seja, sem cumprir sua exata função jurídico-econômica, é um ato preparatório para a lavagem de dinheiro. Uma vez abastecida com recursos de origem criminosa, tem-se a consumação da lavagem.

MARIANO MARCONDES, ainda que não tenha, por si só, ocultado a natureza de bem de origem ilícita, participou e contribuiu de modo fundamental para a lavagem, através da realização de transferência de valores entre as duas *offshores*. Assim **concorre para a ocultação da localização, da movimentação, da propriedade e da origem dos valores.**

Ao inserir o objeto da corrupção ativa no mecanismo de ocultação da sua origem e dissimulação da natureza, mediante transferência do valor de uma *offshore* para outra *offshore*, **MARIANO MARCONDES auxilia, de modo penalmente relevante, HUMBERTO MESQUITA e PAULO ROBERTO COSTA a ocultar a origem e a natureza de recurso provenientes do crime de corrupção**.

MARIANO MARCONDES participa, de modo essencial, do crime de lavagem, de modo que não se pode excluir a sua ação do âmbito da tipicidade do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

Sob outro viés, **não se pode pretender a absorção do crime** de lavagem pelo crime de corrupção, pois **não se trata do meio necessário para a sua realização**.

A lavagem, enquanto delito associado ao crime antecedente, com ele poderá formar algum vínculo causal, sobretudo na primeira fase da lavagem, quando o produto do crime antecedente se encontra ainda muito próximo da origem ilícita. Todavia, **a estratégia de ocultação do produto do crime constitui uma opção acidental no percurso do delito antecedente,** que permite ao beneficiário do seu produto inserir obstáculos para a identificação de sua origem ilícita.

Ainda que se possa caracterizar o primeiro ato de lavagem como praticado em concurso formal com o crime de corrupção, necessariamente haveria de se falar em **concurso formal impróprio, previsto no trecho final do artigo 70 do Código Penal**.

MARIANO MARCONDES argumenta, ademais, que não se pode reconhecer participação relevante de sua parte no crime de lavagem de dinheiro de autoria de PAULO ROBERTO COSTA, uma vez que a **definição do local ou forma de pagamento** seria plena responsabilidade deste último, restando-lhe, unicamente, a opção de cumprir a exigência.

Trata-se de uma hipótese, que o recorrente associa à linha mestra de sua defesa, ou seja, que MARIANO MARCODES é vítima do crime de concussão, de modo que o local

de pagamento da propina, tal qual este, foi objeto de imposição de PAULO ROBERTO COSTA. Todavia, como já analisado acima, tem-se por implausível a hipótese, porquanto dissociada das provas nos autos, que evidenciam a iniciativa do recorrente em buscar, a qualquer preço, a contratação da PETROBRAS, de modo a garantir a sua bonificação pessoal, prometida pela DECAL.

Portanto, deve-se compreender a **escolha do modo de pagamento**, ou seja, os depósitos em conta bancária no exterior, **como uma decisão conjunta, no interesse do corrupto e do corruptor.**

De fato, como se vislumbra de ações conexas na Operação Lava Jato, as transferências **bancárias internacionais não consistiam na única forma de pagamento de propina,** verificando-se, não raro, a transferência de valores em espécie, obras de arte ou pagamentos de despesas pessoais dos corruptos. **Para MARIANO MARCONDES, titular de conta bancária no exterior, a sugestão dada por PAULO ROBERTO COSTA revelava-se igualmente conveniente, garantindo-lhe o sigilo que as operações bancárias envolvendo *offshores* oferecem**.

Assim, não há como se afastar a participação do réu nos atos de lavagem.

Sob outro prisma, o recorrente busca afastar a **tipicidade subjetiva do delito.**

Afirma que a **realização de um dos depósitos através de sua conta pessoal** demonstraria a ausência de pretensão em participar de atos de lavagem, uma vez que o teria feito através de conta bancária que o vincularia diretamente ao ato. Todavia, se referida transferência pudesse trazer alguma dúvida quanto ao dolo do recorrente, o fato de **se limitar a uma das oito transações bancárias descritas na inicial afasta qualquer digressão neste sentido**.

Deve-se destacar que o cerne da imputação do ato de lavagem de dinheiro diz respeito ao depósito em favor de *offshore* controlada pelo genro de PAULO ROBERTO

COSTA, consistindo a utilização de outras *offshores* como fonte dos recursos uma circunstância adicional na prática do delito. Assim, o reconhecimento da utilização da conta pessoal do recorrente em um dos pagamentos não exclui a ocorrência do delito. Nesse caso, **deve-se supor que houve unicamente um descuido por parte do recorrente, que não descaracteriza o fato principal do ato de lavagem, ou seja, o depósito na conta OST INVEST, de HUMBERTO MESQUITA**.

Em relação à **tipicidade objetiva**, MARIANO MARCONDES afirma que é impróprio imputar-lhe o uso de contas no exterior, já que lá residia, e que não haveria atos de ocultação, dada a correta identificação, em conformidade com as normas, dos titulares das contas bancárias na Suíça, inclusive no tocante aos controladores das empresas *offshore* e aos participantes das negociações comerciais, evidenciando o *compliance* da situação concreta.

Ora, o recorrente desvia o foco da conta bancária que recebe os depósitos, de modo a evitar reconhecer que **a conta bancária em nome da *offshore* OST INVEST apontava como beneficiário HUMBERTO MESQUITA, e não PAULO ROBERTO COSTA, efetivo titular dos valores ali aportados**.

Ou seja, a conta bancária, em si, apesar de todos os registros, estava destinada a ocultar ou seu real interessado. O fiel cumprimento da regulação anti-lavagem, a que faz referência o recorrente, é meramente formal. De fato, a adoção de programa de *compliance* pela instituição financeira não modificou a viabilidade da ocultação, da dissimulação, necessárias para a lavagem.

Sintomático, a respeito, a postura do gerente da conta OST INVEST de HUMBERTO MESQUITA em contatar MARIANO MARCONDES, logo após a eclosão da Operação Lava Jato, e a exposição pública de investigações contra PAULO ROBERTO COSTA, como relatado pelo próprio recorrente (evento 119 Termo1 dos autos originários):

> Defesa:- Acho que o interrogatório foi bem completo, faltou só um ponto. Ele esclareceu que não houve contrato com a empresa OST. Foi feito algum documento para

dissimular, para esconder o negócio na época em que eram feitos os depósitos na conta?

Mariano Marcondes Ferraz:- Não, na época em que eram feitos os depósitos nunca foi feito nenhum, nunca teve nenhum tipo de documento. Existia, sim, a pedidos do Humberto, sistemáticos, para que se fizesse o pagamento, eu simplesmente fazia o pagamento na conta que tinha sido dada por ele.

Defesa:- E depois da Lava Jato, foi feito algum documento depois de desencadeada a operação?

Mariano Marcondes Ferraz:- **Sim, então, depois da Lava Jato eu fui procurado por um agente do banco do Humberto, do Banco Lombard Odier, me procurou dizendo que ele precisava ajustar as contas do Humberto e precisava de algum tipo de notas para ele fechar inclusive as contas do Humberto, assim que eu tinha entendido.** E eu, doutor, ingenuamente, acabei... ele me procurou, eu atendi o telefone, eu vi uma pessoa ligando de um banco, acabei atendendo o telefone, nós todos somos bastante acessíveis. Eu atendi, marquei um encontro, ele me colocou essa situação, e uma semana ou 10 dias depois, eu entreguei umas faturas para ele, equivalentes aos pagamentos que tinham sido feito. Fiz de uma forma ingênua, é verdade, porque na realidade inclusive até eu repensando, e quando eu li todos os fatos, a fatura é trocada, quer dizer, não faz sentido, quer dizer, eles tinham que me emitir uma fatura, eu acabei entregando 8 faturas, quer dizer, sem sentido, com os valores que ele tinha me pedido, ele queria, enfim, regularizar a conta do Humberto, ou fechar a conta do Humberto, e eu, ingenuamente, acabei entregando faturas pra ele.

Ou seja, antevendo que seus superiores iriam exigir a comprovação da sua observância aos deveres de prevenção à lavagem, e apontar o *compliance* na gestão financeira, o agente do Banco Lombard Odier vai atrás dos documentos que não exigiu à época dos depósitos realizados pelo recorrente, revelando que pouco se importava em verificar a identidade dos reais interessados no negócio e a existência de motivação econômica para a aquela transação. Nessa linha, falar em *compliance* para afastar a tipicidade objetiva do delito é risível.

Ademais, **o uso de empresas *offshores* é inegavelmente um mecanismo para ocultar a propriedade de ben**s. Apesar de constar, perante a instituição financeira, o cadastro do responsável pela empresa – e no presente caso, este cadastro era ideologicamente falso! - o registro bancário em nome de uma empresa **dificulta aos órgãos de investigação ou de regulação**

bancária a identificação dos reais envolvidos nas transações bancárias e facilita a apresentação de justificativas econômicas para as transações realizadas.

Imagine-se, o contrário, que PAULO ROBERTO COSTA recebesse em seu próprio nome a quantia de US$ 870 mil, oriundas da conta de MARIANO MARCONDES, agente comercial de empresas contratadas pela PETROBRAS. Ora, o risco de identificação da transação ilícita imputada ambos seria muito superior. Ao passo que a transferência de valores da TIK TRADING, FIRMA INVEST e FIRMA PART para a OST INVEST, nada diz. Só após a quebra do sigilo bancário, procedimento com exigências legais próprias, se logra identificar os sujeitos realmente proprietários destas contas bancárias.

Ainda no espectro objetivo do tipo, o recorrente alega que não é possível falar-se lavagem, pois não teria havido **integração dos valores à economia formal**.

Todavia, o depósito bancário na conta *offshore* integra o conjunto de atos que caracterizam o ciclo da lavagem de dinheiro, cujo propósito de integração dos valores à economia real está evidenciado pela busca da legitimação da renda recebida e do patrimônio mantido.

A ausência de demonstração da aquisição de algum bem, da realização de um investimento etc, apenas significa que a lavagem não atingiu a sua fase final, mas **não afasta a tipificação do ato, dada a caracterização do crime como sendo de *ação múltipla, com núcleos disjuntivos, de forma que a realização de qualquer das condutas descritas concretiza a consumação***[3].

Ademais, não se pode deixar de reconhecer que também faz parte das estratégias de ocultação, a manutenção dos valores em determinada conta bancária ao longo do tempo, para que os valores venham a ser investidos em outras atividades após certo distanciamento temporal dos eventos ilícitos que os geraram.

[3] BOTTINI, Pierpaolo Cruz; BADARÓ, Gustavo Henrique. Lavagem de Dinheiro. São Paulo: RT, 2013 pp. 65/66.

Superados estes pontos, convém esclarecer a situação relacionada **às sete *invoices,* juntadas nos autos após o ajuizamento da denúncia** (evento 60 dos autos originários).

De fato, a denúncia (evento 1 DEN1 p. 10/13) não narra, como uma das circunstâncias da prática da lavagem, a apresentação destes documentos à instituição financeira para subsidiar as transações bancárias. **Trata-se, entretanto, unicamente de uma circunstância acessória da imputação. Esta é voltada ao acerto realizado entre MARIANO MARCONDES e PAULO ROBERTO COSTA para que o depósito das vantagens indevidas fosse feito na conta mantida pela offshore de titularidade de HEMBERTO MESQUITA**. Não se fala em dissimulação da prestação de serviços, ainda que as provas aportadas à ação penal assim o demonstrem.

Nesse sentido, tais documentos devem servir apenas como referência probatória da lavagem imputada, sem constituir-se em fatos novos imputados aos réus.

Portanto, todas as discussões acerca do dolo do recorrente, da punibilidade desta conduta ou da idoneidade dos documentos para a prática da lavagem da conduta para os atos é desnecessária.

Por tais razões, deve ser mantida a condenação de MARIANO MARCONDES pelo crime de lavagem de dinheiro.

II.2.1.3 – Da dosimetria

Quanto à **dosimetria**, o apelante sustenta, em relação à fixação da pena base do *crime de corrupção ativa*, a impossibilidade de incremento da pena em razão do valor da

propina, a título de circunstâncias do crime, pois o valor é substancialmente inferior a outros casos julgados na Operação Lava Jato, de modo que não justificaria o incremento de 6 meses na pena; a necessidade de reconhecer uma culpabilidade favorável, que justifique a atenuação da pena, tendo em vista as circunstâncias que levaram-no a praticar o delito; ser indevida a diminuição da pena em apenas 3 meses, pelo reconhecimento da confissão parcial, tendo em vista o teor da Súmula 545 STJ, sendo irrelevante a discordância quanto a sua ilicitude, bem como sustenta ser inaplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 317, §1° do CP.

Não assiste razão ao recorrente.

O **valor da propina paga pelo recorrente, totalizando quase US$870 mil, não é irrisório**, ainda que seja substancialmente inferior a outros fatos imputados no âmbito da Operação Lava Jato, de modo que justifica o incremento da pena base.

Ensina a doutrina que as circunstâncias do crime previstas no artigo 59 do Código Penal *defluem do próprio fato delituoso, tais como a forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meio utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes*[4].

O valor da propina é nitidamente um aspecto acidental do crime que não é objeto de valoração em nenhum outro dispositivo do Código Penal. Corresponde ao objeto do crime de corrupção e pode variar de poucas centenas de reais, pagos para evitar uma autuação por um agente de trânsito, até cifras milionárias vinculados a contratos de altíssimo valor. A busca por uma vantagem econômica indevida extraordinária dá ensejo a uma reprovação penal agravada, como forma de compensar, de modo inversamente proporcional, o maior proveito obtido com o ilícito.

O STJ possui entendimento acerca da possibilidade de graduar a pena base do crime de corrupção, a partir do valor da propina:

> HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.
> 1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista

[4] Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 556.

> previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.
> (...)
> DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
> 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o exame da dosimetria da pena por meio de habeas corpus somente é possível quando evidenciado de plano, sem a necessidade de exame de provas, flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu.
> 2. No caso dos autos, não se constata qualquer abuso ou irregularidade na dosagem da sanção cominada ao acusado, tendo a autoridade apontada como coatora declinado motivos concretos aptos a justificar a elevação da pena que lhe foi imposta, sendo certo que tanto o modus operandi por ele e o corréu empregado, quanto **o expressivo valor da propina solicitada, além do fato de que já atuaria com outros fiscais tributários há muito tempo, não constituem elementos inerentes ao tipo penal infringido, evidenciando a maior reprovabilidade do fato ilícito praticado**.
> 2. Tratando-se de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a sua substituição por reprimendas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
> (HC 303.925/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, não é razoável que a mesma pena seja imposta situações que envolvem uma grande distinção no valor da propina. Todavia o patamar de aumento considerado para a pena aplicada ao réu é adequado para o montante de propina paga, não sendo o caso alterá-lo.

Por outro lado, **não há que se falar em valoração da vetorial culpabilidade de modo positivo, para mitigar a pena-base**. Somente as circunstâncias que revelem potencial de exasperar a pena base são levadas em consideração na primeira fase da dosimetria, a fim de justificar pena superior ao mínimo legal, como aponta a jurisprudência do STJ:

> PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 155, 156, 214 E 386, VII, TODOS DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 59 DO CP E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
> 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto

> condenatório, ou a ensejar a absolvição. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
> 2. "Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal." (STF - RHC 101576, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012)

No julgamento deste Agravo em Recurso Especial, a Ministra Relatora esclareceu:

> "Ademais, **não há que se falar em compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis**, porquanto o que se leva em consideração no aumento da pena-base é tão somente a existência de circunstâncias desfavoráveis, na proporção em que se apresentam, sendo que a análise favorável das circunstâncias judiciais somente tem o condão de manter a reprimenda no mínimo legal."

Neste sentido, não há porque discutir quanto ao eventual conteúdo favorável da culpabilidade apresentada no recurso. Além de ser um pleito de questionável legalidade, o recorrente faz alusão a circunstâncias que não são confirmadas com a prova dos autos, como amplamente analisado (supra).

No tocante à **atenuação da pena, em razão da confissão**, tampouco assiste razão ao recorrente.

A adoção da fração de 1/6 da pena, como patamar de atenuação resultante do reconhecimento da confissão, aplica-se quando não estão presentes motivos para que seja reduzida a pena-base em quantidade distinta. Assim, não há que se falar em um montante fixo para a atenuação da pena. Tão somente se veda, a adoção de patamar distinto de 1/6, se não houver fundamentação para tanto, como se vê na jurisprudência do STJ:

> PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ROUBO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM DADOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS.

LEGALIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECEPTAÇÃO. SEGUNDA FASE DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO QUE NÃO PRODUZIRIA EFEITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Sobre dosimetria, cumpre enfatizar que o eg. Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016).

III - A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro das balizas legais, deve eleger, de modo fundamentado, a quantidade ideal a ser aplicada ao condenado, tendo em vista a prevenção e a repressão ao crime praticado. IV - Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, ainda que não configure reincidência, permite a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

V - In casu, não há que reconhecer desproporção na pena-base aplicada ao delito de roubo, uma vez que há motivação particularizada, para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e dos antecedentes do paciente, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

VI - Do mesmo modo, devidamente fundamentada a majoração em 1/2 (metade) ao reconhecer as majorantes previstas no §2°, I, II e V, do art. 157 do Código Penal, quais sejam, o delito cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade das vítimas por longo período de tempo.

VII - O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. **Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a diminuição da pena em fração inferior a 1/6, pela aplicação da atenuante da confissão, deve ser fundamentada.**

VIII - No que concerne ao delito de receptação do veículo GM/S10, o eg. Tribunal de origem a reduziu em apenas 1/8 (um oitavo), por ocasião da confissão, sem que houvesse fundamentação para tanto, incorrendo em flagrante ilegalidade.

IX - No entanto, constatada a continuidade delitiva entre os crimes de receptação, deve a pena mais grave, qual seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses - referente à receptação do veículo Hyundai/HB20 - ser majorada em 1/6 (um sexto), de forma que, a redução da pena do delito relacionado à receptação do veículo GM/S10, em decorrência da

> aplicação da fração de 1/6 (um sexto) resultante da confissão, em nada influiria no quantum definitivo cominado, de modo que, deixo de procedê-la.
> Habeas corpus não conhecido.
> (HC 423.573/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
>
> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. SUM. 7/STJ.
> CONFISSÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> 1. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou os delitos pelos quais foi denunciado, chegar a entendimento diverso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
> 2. Ademais, "A Lei n.º n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
> 3. A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser concretamente fundamentada.
> Na hipótese, a pena foi reduzida em 1/4 (6 meses), acima, portanto, do que vem entendendo a jurisprudência desta Eg. Corte, não havendo que se falar em ilegalidade na dosimetria.
> 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
> (AgRg no REsp 1695882/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)

No presente caso, a sentença aponta que a confissão do recorrente é parcial, porque admite os pagamentos, mas nega ter adotado iniciativa em oferecer ou prometer a propina, sustentando, falsamente, ter sido vítima de concussão. De fato, trata-se de uma versão dos fatos que altera totalmente o cenário de sua responsabilização penal, de modo que está muito distante de uma confissão plena.

Nesse sentido, deve ser mantida a atenuação da pena no patamar apresentado.

Em relação à incidência da **causa de aumento de pena prevista no artigo 317, §1° do Código Penal**, por se tratar de matéria que se confunde com o objeto da apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, deixa-se que seu exame seja feito numa única oportunidade (infra).

Quanto ao *crime de lavagem de dinheiro*, sustenta a inexistência de especial sofisticação nos atos de lavagem de dinheiro, sobretudo em consideração às observações feitas sobre as reais condições da prática dos atos imputados a título de lavagem, devendo ser afastada a desqualificação da vetorial circunstâncias; que o valor das operações financeiras não justificam, concretamente, a desqualificação da vetorial consequências; que as duas vetoriais não justificariam o incremento de 1 ano e 6 meses da pena, notadamente se comparada a outros casos julgados na Operação Lava Jato; a necessidade de reconhecer uma culpabilidade favorável, que justifique a atenuação da pena, tendo em vista as circunstâncias que levaram-no a praticar o delito; ser indevida a diminuição da pena em apenas 3 meses, pelo reconhecimento da confissão parcial, tendo em vista o teor da Súmula 545 STJ, sendo irrelevante a discordância quanto à ilicitude dos fatos; bem como sustenta ser aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 1º, §5° da Lei 9.613/98, em razão de sua colaboração com as investigações; e que deve ser afastada a caracterização da prática de 8 crimes de lavagem, em continuidade delitiva, porquanto se trata de crime único, vinculado a um único crime de concussão praticado por PAULO ROBERTO COSTA.

Não assiste razão ao recorrente.

Ao contrário do que afirma, houve sofisticação da prática da lavagem, a ponto de subsidiar a exasperação da pena base. Não é possível banalizar o uso de empresas *offshore* e de contas mantidas no exterior, que dão ao crime um nível especial de proteção contra as investigações criminais, permitindo maior sucesso na reintegração dos valores à economia formal.

Sabe-se que o **processo de constituição de uma *offshore* e de abertura de contas no exterior envolve uma série de providências burocráticas**, geralmente atribuídas a

escritórios especializados, evidenciando um arranjo jurídico mais trabalhoso, que deve ser gravado por uma pena maior.

Assim, deve ser mantida a desqualificação da vetorial.

Da mesma forma, o **valor da lavagem está longe de ser desprezível**.

Para a valoração das consequências do crime, a referência ao montante ocultado é um elemento adequado para justificar a desconsideração da vetorial, na medida em que o maior volume de recursos corresponde à maior satisfação dos objetivos da lavagem de dinheiro praticada, ou seja, a transferência de recursos entre pessoas sem a devida identificação da natureza das transações que as embasam.

Trata-se de situação muito semelhantes àquela que foi decidida recentemente no âmbito do Recurso Especial n° 1631431, julgado em 16/04/2018, Rel. FELIX FISCHER, e que deve ser replicada no presente caso:

> "Quanto às circunstâncias do delito, assinalaram as instâncias ordinárias a presença de um engenhoso e sofisticado esquema de evasão de dinheiro, com a abertura e utilização de contas em off-shores ou de pessoas interpostas em instituição financeira, o First Curaçao International Bank, com sede nas Antilhas Holandesas, instituição posteriormente fechada pelas próprias autoridades holandesas.
>
> No que concerne às consequências do delito perpetrado, entenderam graves as instâncias ordinárias o expressivo valor evadido (cerca de US$ 10.866.615,48).
>
> Reputo idônea e individualizada a fixação da pena-base, nos exatos termos pontuados pelas instâncias a quo."

Ainda que se trate de crime de evasão de divisas, está salientado que a sofisticação das operações e o valor destas são parâmetros adequados para a delimitação da pena-base de crimes financeiros, o que é extensível para a lavagem de dinheiro.

Ambos os elementos são capazes de justificar o incremento da pena-base definido na sentença recorrida, não se revelando desproporcionalidade que justifique a sua alteração.

Por outro lado, **não há que se falar em valoração da vetorial culpabilidade de modo positivo, para mitigar a pena-base**. Somente as circunstâncias que revelem potencial de exasperar a pena base são levadas em consideração na primeira fase da dosimetria, a fim de justificar pena superior ao mínimo legal, como aponta a jurisprudência do STJ:

> PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 155, 156, 214 E 386, VII, TODOS DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 59 DO CP E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
> 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
> 2. "Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal." (STF - RHC 101576, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012)

No julgamento deste Agravo em Recurso Especial, a Ministra Relatora esclareceu:

> "Ademais, **não há que se falar em compensação entre circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis**, porquanto o que se leva em consideração no aumento da pena-base é tão somente a existência de circunstâncias desfavoráveis, na proporção em que se apresentam, sendo que a análise favorável das circunstâncias judiciais somente tem o condão de manter a reprimenda no mínimo legal."

Neste sentido, não há porque discutir quanto ao eventual conteúdo favorável da culpabilidade apresentada no recurso. Além de ser um pleito de questionável legalidade, o recorrente faz alusão a circunstâncias que não condizem com a inequívoca ocultação do vínculo de

PAULO ROBERTO COSTA com as contas bancárias onde realizados os depósitos, como amplamente analisado (supra).

No tocante à **atenuação da pena, em razão da confissão**, tampouco assiste razão ao recorrente.

A adoção da fração de 1/6 da pena, como patamar de atenuação resultante do reconhecimento da confissão, aplica-se quando não estão presentes motivos para que seja reduzida a pena-base em quantidade distinta. Assim, não há que se falar em um montante fixo para a atenuação da pena. Tão somente se veda, a adoção de patamar distinto de 1/6, se não houver fundamentação para tanto, como se vê na jurisprudência do STJ:

> PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ROUBO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM DADOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECEPTAÇÃO. SEGUNDA FASE DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 EM VIRTUDE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO QUE NÃO PRODUZIRIA EFEITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
> I - (...)
> VI - Do mesmo modo, devidamente fundamentada a majoração em 1/2 (metade) ao reconhecer as majorantes previstas no §2°, I, II e V, do art. 157 do Código Penal, quais sejam, o delito cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade das vítimas por longo período de tempo.
> VII - O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. **Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a diminuição da pena em fração inferior a 1/6, pela aplicação da atenuante da confissão, deve ser fundamentada.**
> VIII - No que concerne ao delito de receptação do veículo GM/S10, o eg. Tribunal de origem a reduziu em apenas 1/8 (um oitavo), por ocasião da confissão, sem que houvesse fundamentação para tanto, incorrendo em flagrante ilegalidade.

> IX - No entanto, constatada a continuidade delitiva entre os crimes de receptação, deve a pena mais grave, qual seja, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses - referente à receptação do veículo Hyundai/HB20 - ser majorada em 1/6 (um sexto), de forma que, a redução da pena do delito relacionado à receptação do veículo GM/S10, em decorrência da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) resultante da confissão, em nada influiria no quantum definitivo cominado, de modo que, deixo de procedê-la.
> Habeas corpus não conhecido.
> (HC 423.573/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)
>
> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. SUM. 7/STJ.
> CONFISSÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> 1. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou os delitos pelos quais foi denunciado, chegar a entendimento diverso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
> 2. Ademais, "A Lei n.º n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).
> 3. **A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser concretamente fundamentada.** Na hipótese, a pena foi reduzida em 1/4 (6 meses), acima, portanto, do que vem entendendo a jurisprudência desta Eg. Corte, não havendo que se falar em ilegalidade na dosimetria.
> 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
> (AgRg no REsp 1695882/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)

No presente caso, a sentença aponta que a confissão do recorrente é parcial, porque admite os pagamentos, mas nega a intenção de ocultar o destino dado aos recursos, sustentando, falsamente, que não teria participação na definição do modo de pagamento da propina.

Nesse sentido, deve ser mantida a atenuação da pena no patamar apresentado.

Ademais, o recorrente alega que deve ser reconhecida a sua colaboração com as investigações, aplicando a **causa de diminuição da pena prevista no artigo 1°, §5° da Lei 9.613/98**.

O recorrente leva ao paroxismo a sua parcial confissão, ao dirigir referida pretensão.

A colaboração com as investigações tem objeto distinto da confissão. Envolve, sobretudo, o auxílio às autoridades da persecução penal na identificação e comprovação de outros crimes, além daqueles que são investigados. Portanto, não é suficiente que o recorrente aponte ter ficado à disposição dos investigadores, e ter confirmado que as contas indicadas no seu interrogatório efetivamente lhe pertenciam. É necessário mais, que o réu traga ao conhecimento da autoridade investigativa elementos que não são de seu conhecimento, envolvendo outros agentes criminosos ou outros cenários de criminalidade, ainda não alcançados pela investigação.

Por tanto, não há base para o reconhecimento da colaboração do recorrente.

Por fim, sustenta que deve ser **afastada a caracterização da prática de 8 crimes de lavagem, em continuidade delitiva**, porquanto se trata de crime único, vinculado a um único crime de concussão praticado por PAULO ROBERTO COSTA.

A vinculação ao crime antecedente não é o critério adequado para quantificar a ocorrência de delitos de lavagem de dinheiro. Dada sua autonomia jurídica, a materialização e consumação típica da lavagem deve ser avaliada dentro da especificidade de sua própria ocorrência, sem levar em consideração se a infração antecedente constitui crime único ou se há concurso de delitos.

Nesse sentido, cumpre avaliar, sobretudo, se os fatos descritos a título de lavagem de dinheiro constituem um só todo, ou se é composto de uma diversidade de condutas que se somam.

Exemplo típico do primeiro caso é a estruturação de depósitos, geralmente em valores inferiores a um padrão fixado pelas autoridades financeiras para guiar a fiscalização bancária, em que a estratégia de ocultação está associada à diversidade de depósitos. Neste caso, é o conjunto de depósitos fracionados que materializam a lavagem e, portanto, autorizam a tipificação como crime único.

Por sua vez, a diversidade de condutas, por sua vez, pode se revelar em diversas formas, como se vê, por exemplo, na dissimulação da propriedade de distintos bens imóveis adquiridos ao longo do tempo. Em relação a cada um dos imóveis, estará configurada uma prática de lavagem de dinheiro.

No caso em exame, oito depósitos se sucedem ao longo de quatro anos, com um intervalo relativamente regular de alguns meses entre si, destinados a conta mantida por empresa *offshore* de titularidade de pessoa interposta.

Aqui, não há como se falar em fracionamento do pagamento, como estratégia de lavagem. O longo intervalo entre os depósitos e a ausência de um valor teto de referência indicam que cada um dos depósitos possui autonomia própria, de modo que a sua separação está relacionada à disponibilidade financeira de MARIANO MARCONDES e à continuidade do contrato entre DECAL e PETROBRAS.

Assim, cada um dos depósitos deve ser visto como um ato em si de lavagem, porquanto, isoladamente, poderiam justificar a incidência do tipo penal em questão, devendo ser afastada a alegação de crime único.

Por fim, quanto à **pena de multa**, afirma que não houve fundamentação para a definição do número de dias-multa.

A primeira fase de fixação da pena de multa deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade, como estatui o artigo 59, II do CP. Adoutrina aponta para a

proporcionalidade entre a gravidade atribuída ao crime em julgamento e a definição da quantidade de dias-multa[5].

A exposição do raciocínio matemático que leva ao resultado de proporcionalidade não nos parece ser uma exigência a ser imposta à sentença, como condição de validade da sua fundamentação. Deve haver apenas a proporcionalidade, podendo a defesa ou a acusação expor, mediante demonstrações matemáticas, que a proporcionalidade não foi obedecida.

No presente caso, a pena de multa foi fixada abaixo do que poderia ter sido, conforme se observa a seguir.

Para o crime de corrupção ativa, a pena privativa de liberdade aplicada a MARIANO MARCONDES é de 3 anos e 3 meses. O que significa que foi adotado um incremento de pena pouco superior a 1/8 do intervalo total cominado (2 – 12). A pena de multa foi fixada em 45 dias-multa, um incremento de 35 dias-multa, o que é inferior ao incremento necessário para garantir a proporcionalidade, ou seja, 1/8. Assim, se a multa fosse seguir à risca a pena privativa de liberdade, deveria ter sido fixada em 54 dias-multa, resultante do incremento de 1/8 sobre o intervalo total cominado (10 – 360) para a pena de multa (350/8=43,75).

Para o crime de lavagem de dinheiro, a pena privativa de liberdade aplicada a MARIANO MARCONDES é de 7 anos e 1 mês. O que significa que foi adotado um incremento de pena equivalente a 7/12 do intervalo total cominado (3 – 10). A pena de multa foi fixada em 100 dias-multa, um incremento de 90 dias-multa, o que é muito inferior ao incremento necessário para garantir a proporcionalidade, ou seja, 7/12. Assim, se a multa fosse seguir à risca a pena privativa de liberdade, deveria ter sido fixada em 214 dias-multa, resultante do incremento de 7/12 sobre o intervalo total (10 – 360) cominado para a pena de multa (350*7/12=204).

Por tais razões, deve ser afastado o questionamento.

[5] https://www.conjur.com.br/2017-jul-27/cezar-bitencourt-calculo-pena-multa-segundo-reforma-penal, acesso em 06/09/2018.

II.2.1.4 – Ressarcimento dos danos e confisco

Em relação ao **valor da reparação mínima dos danos**, sustenta, inicialmente, que não há qualquer demonstração do prejuízo à PETROBRAS, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mesmo sentido, no tocante ao **confisco do valor dado em fiança**, sustenta que não há que se falar em produto ou proveito auferido com o crime, de modo que não houve fundamentação para a decisão.

A fixação da reparação mínima dos danos, em casos envolvendo o pagamento de "comissão" para a celebração do contrato, *kickback*, como no presente caso, infere-se de sua lógica econômica, onde se vislumbra que a oferta pela empresa contratada de um valor ao funcionário da empresa contratante reflete-se nas condições comerciais apresentadas por aquela empresa. Esse reflexo é, invariavelmente, traduzido na imposição de um custo à contratante, no caso a PETROBRAS.

No presente caso, entretanto, não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS. Não se identifica nos autos a interferência ilícita nas negociações comerciais, que viesse a impor algum custo extra à PETROBRAS, como se viu em contratos firmados pela Diretoria Internacional, e que representavam a incorporação da "comissão" ao preço a ser pago pela PETROBRAS. Tampouco se viu a incorporação dos valores pagos em itens de difícil mensuração, como verificado em orçamentos apresentados pelas empreiteiras cartelizadas. Portanto, não há elementos para demonstrar o prejuízo da PETROBRAS.

Como amplamente desenvolvido no tópico referente à corrupção ativa (supra) MARIANO MARCONDES, na qualidade de representante da empresa DECAL, recebeu uma oferta de remuneração, condicionada à captação de novos clientes para as instalações da empresa no porto de SUAPE. Para viabilizar a contratação pela PETROBRAS, e garantir a sua própria remuneração, ofereceu e pagou propina a PAULO ROBERTO COSTA.

De acordo com o depoimento do recorrente, o pagamento da propina teria saído desta remuneração prometida pela DECAL. Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção

e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas, diminuindo o seu próprio ganho.

Se isto afasta a plausibilidade da fixação de danos mínimos à PETROBRAS, entretanto, permite concluir que **MARIANO MARCONDES foi beneficiado pela prática da corrupção ativa.**

Ao oferecer vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, o recorrente tinha em vista a comissão que lhe fora prometida pela DECAL. Ao agir de modo ilícito para garantir a celebração do contrato e o recebimento da comissão prometida a MARIANO MARCONDES, deve-se concluir que esta comissão paga pela DECAL ao recorrente corresponde ao valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Tal valor, nos termos do artigo 91, II, b) do Código Penal, **está sujeito ao confisco e perdimento em favor da União**, razão pela qual deve ser mantida a ordem de confisco sobre o montante da vantagem indevida, uma vez ausente recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para ampliar o valor.

Em conclusão, o parecer é pelo *parcial provimento* da apelação do réu MARIANO MARCONDES, unicamente para afastar a fixação de indenização mínima, mantendo-se a pena de confisco.

II.2.2 – Da apelação da acusação

As razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de primeira instância (e. 157) trazem pleito pela reforma em parte da sentença, postulando, a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade negativa; a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 333, parágrafo único do Código Penal, tendo em vista a atuação de PAULO ROBERTO COSTA na agilidade da renovação do contrato, com o propósito de receber a propina; a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 1°, § 4° da Lei 9.613/98, em razão da realização de 8 depósitos ao longo do prazo de três anos, mediante mecanismo sofisticado, o que revelaria profissionalismo criminoso e contra o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de lavagem, porquanto o uso de três *off-shores*, ao longo de três anos, não permitiria a conclusão de circunstâncias semelhantes, exigidas pelo artigo 71 do Código Penal.

Dosimetria

A acusação busca alterar a dosimetria da pena aplicada ao réu, revendo uma circunstância judicial, a culpabilidade, sustentando a aplicação de duas causas de aumento de pena, previstas no artigo 333, parágrafo único do CP e no artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98 e pugnando pelo afastamento da continuidade delitiva do crime de lavagem.

Sustenta a acusação que a **c**ulpabilidade deve servir para o agravamento da pena, uma vez que MARIANO MARCONDES, na qualidade de representante da DECAL, agiu com dolo intenso, com inequívoca consciência da ilicitude da conduta, reiterada diversas vezes através de sofisticados mecanismos financeiros. Ressalta seu elevado grau de escolaridade e destacada posição socioeconômica, revelando alto nível de discernimento quanto aos atos praticados.

Com razão, em que pese a sentença ter reputada neutra a culpabilidade, a perspectiva apresentada pela apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é adequada, justificando reputar desfavorável a culpabilidade de MARIANO MARCONDES.

Na qualidade de responsável pela negociação de novas contratações da empresa DECAL, MARIANO MARCONDES possuía autonomia para buscar clientes para a estrutura de tancagem no porto de SUAPE. Ao buscar operadores financeiros com notória atuação na facilitação de contratos mediante pagamento de "comissões", o recorrente buscou meio ilícito para garantir um contrato que lhe renderia vultosa remuneração. Titular de parcela inexpressiva do capital social da filial brasileira da empresa DECAL, MARIANO MARCONDES estava em condições de recusar-se a participar das práticas corruptas na PETROBRAS.

Assim, deve ser **provido o recurso da acusação, no ponto, para desqualificar a vetorial culpabilidade**.

Relativamente à aplicação da **causa de aumento de pena prevista no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal**, o recorrente argumenta o seguinte:

> " (…)
>
> Assim como dito por PAULO ROBERTO COSTA em seu interrogatório, foi reconhecido na r. sentença que **o então Diretor da PETROBRAS interferiu na celeridade da tramitação interna com que o contrato fora renovado.** Em razão do elevado cargo na Diretoria, estava inserido nos poderes de fato de PAULO ROBERTO COSTA sua atuação em face da celebração do instrumento, sendo um ato eminentemente funcional.
>
> **Ainda que a mera interferência na rapidez da assinatura não represente, por si só, ilegalidade no ato de ofício,** já que, em tese, seria ínsita à própria função pública desempenhada, o **plano de fundo com que exercida estava amplamente associada à pretensão criminosa de recebimento de valores indevidos oferecidos, prometidos e efetivamente pagos pelo apelado.**
>
> (...)
>
> **Resta claro que a conduta do agente público corrompido, embora aparentemente**

lícita, foi movida pela finalidade criminosa de recebimento dos valores repassados pelo apelado, em uma típica relação de contrapartida entre modalidades bilaterais dos crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva, comprovando que as vantagens indevidas recebidas por PAULO ROBERTO COSTA foram pagas devido à sua influência administrativa para a contratação da DECAL DO BRASIL.

Portanto, **o ato de ofício foi praticado com infração ao dever funcional na medida em que essa conduta violou toda a cadeia de deveres constitucionais e legais a serem observados pelo agente público, especialmente a moralidade e a impessoalidade administrativas.**

Situação análoga ocorreu no julgamento da apelação criminal nº 5023121-47.2015.4.04.7000, na qual o e. Relator aplicou a causa de aumento do crime de corrupção ativa pela infração do dever funcional oriunda de influência indevida motivada pela oferta de propina:

> "Na hipótese dos autos, as provas e indícios carreados aos autos são suficientes a demonstrar, acima de uma dúvida razoável, que o ato de ofício foi praticado, infringindo-se dever funcional. Assim, pode-se dizer que trata-se de corrupção exaurida. Conforme exaustiva fundamentação anterior, RICARDO HOFFMANN ofereceu vantagem indevida a ANDRÉ VARGAS, que a recebeu, em troca da utilização da influência política deste para a contratação da Borghi Lowe pela CEF e peloMinistério da Saúde. Dessa forma, o então Deputado Federal efetivamente praticou ato de ofício infringindo dever funcional, porquanto as assinaturas e renovações dos contratos com as entidades públicas foram realizadas por influência de ANDRÉ, que permaneceu recebendo a propina por quase quatro anos.
> Assim, ao contrário do que decidiu o magistrado singular, entendo aplicáveis as causas de aumento previstas nos artigos 317, §1º, do CP a ANDRÉ VARGAS e 333, parágrafo único, do CP a RICARDO HOFFMANN, devendo ser provido o apelo ministerial no ponto." (grifos nossos)

Assim, mostra-se cabível a aplicação da causa de aumento correspondente ao delito de corrupção ativa, diante da existência de prova da infração do dever funcional pelo agente público, motivo pelo qual pugna-se pela majoração da pena-base imposta na r. sentença.

A pretensão não merece acolhida.

A causa de aumento de pena do crime de corrupção, seja em relação ao artigo 317 ou ao artigo 333 do Código Penal, diz respeito não mais ao potencial desvio da

legalidade das atividades estatais, mas à efetiva concretização de um ato ilegal ou de uma omissão de um dever de agir.

A argumentação apresentada pelo recorrente sustenta que deve ser reconhecida a causa de aumento, uma vez que PAULO ROBERTO COSTA teria garantido a celeridade na contratação da DECAL sob influência da promessa de propina. Ou seja, embora não houvesse a demonstração da ilegalidade da celebração do contrato, o então Diretor de Abastecimento teria agido por razões ilegais, ou seja, para o recebimento das vantagens indevidas.

A situação em exame não nos parece suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena.

Ao contrário do que evidenciado em diversos contratos da PETROBRAS investigados no âmbito da Operação Lava Jato, como contratos firmados com as empreiteiras cartelizadas, para a aquisição dos direitos de exploração do campo de Benin e para a operação do navio sonda VICTORIA 10000, por exemplo, onde ficou evidenciado como houve a interferência de gerentes ou diretores da PETROBRAS para alterar condições comerciais, para superdimensionar vantagens ou para impedir a concorrência na disputa pelo contrato, **no presente caso, a investigação limitou-se a apontar o apoio ou o encaminhamento por PAULO ROBERTO COSTA da contratação**.

De acordo com elementos constantes nos autos, **a contratação das instalações da DECAL em SUAPE seria de interesse da PETROBRAS e as condições comerciais seriam vantajosas**. Não há elementos para afastar tais apontamentos.

A pretendida aplicação da causa de aumento de pena somente se justifica quando se verifica algo além do pagamento da propina: seja a omissão de um dever, seja a prática de um ato ilegal. Considerar o recebimento da propina como ilegalidade suficiente que justifique a aplicação da causa de aumento de pena constitui uma tautologia que praticamente esvazia a distinção entre a forma típica prevista no *caput* do artigo 333 do CP e no seu parágrafo único.

Assim, a circunstância que pode fundamentar o incremento da pena não reside na motivação espúria (expectativa de propina) para a prática de um ato lícito, mas no vício constatado no próprio ato de ofício ou na omissão de um dever de agir. Por tais razões, diante da ausência de prova acerca da ilegalidade da contratação da DECAL, não se justifica a aplicação da causa de aumento de pena.

Assim, não deve ser **provido, no ponto, o recurso da acusação**.

Relativamente à aplicação da causa de **aumento de pena prevista no artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98**, argumenta o apelante que MARIANO MARCONDES realizou oito operações de lavagem, ao longo de quatro anos, com a transferência dos valores a partir de três contas diversas.

Os elementos trazidos pela acusação não são suficientes para justificar a aplicação da citada causa de aumento de pena. A prática de oito atos de lavagem de dinheiro, ao longo de quatro anos, não nos parece suficiente para justificar a caracterização dos atos como "lavagem de dinheiro de forma reiterada".

Assim, não deve ser **provido, no ponto, o recurso da acusação**.

Por fim, argumenta o recorrente **contra o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de lavagem**, porquanto o uso de três *off-shores*, ao longo de três anos, não permitiria a conclusão de circunstâncias semelhantes, exigidas pelo artigo 71 do Código Penal.

O crime continuado tem lugar "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes" (art. 71, CP).

Segundo Cláudio Brandão, em se tratando de concurso de crimes, o concurso material é aplicável por eliminação, sendo cabível quando não couber a incidência das

regras relativas ao crime continuado ou ao concurso formal. A pluralidade de comportamentos, que caracteriza tanto o concurso material como a continuidade delitiva, se distingue, neste último caso, pela existência por um liame ideal de continuidade, que pode ser referente às mais diversas situações, como o tempo, lugar, modo de execução etc.[6]

Juarez Cirino dos Santos, todavia, afirma que a adoção do modelo finalista pela Parte Geral do Código Penal implica a constituição de elementos objetivos e subjetivos nos crimes continuados. Se o aspecto objetivo é composto da equivalência do bem jurídico atingido e da semelhança dos caracteres comuns de tempo, lugar, modo de execução etc, o aspecto subjetivo é indicado por um "*dolo unitário* abrangente do conjunto das ações típicas em continuação". Se fala, então, em dolo de continuação, representante da mesma falha psíquica do autor na mesma situação de fato, no programa ou projeto de realizar uma série mais ou menos determinável de crimes em condições comuns de tempo lugar, modo de execução etc. [7]

No presente caso, há elementos que permitem identificar circunstâncias objetivas semelhantes entre os oito atos de lavagem, de modo a caracterizar a continuidade delitiva. Todos os depósitos foram realizados numa única conta offshore, mantida pelo genro de PAULO ROBERTO COSTA, em razão de um único ato de corrupção. Os depósitos foram realizados em intervalo de tempo relativamente similar (poucos meses), de modo que há muitos elementos objetivos em comum.

A presença do dolo de continuidade também se verifica, na medida em que a denúncia aponta um crime antecedente único, que orienta, justifica e delimita os atos de lavagem.

Embora os crimes possuam potencialidades lesivas próprias, de modo que cada um dos atos de lavagem seja relevante por si só, a justificar de per si a punição, isto não afasta a continuidade delitiva. Nesse sentido, a sentença apresenta-se correta em afastar o cúmulo material de condutas, aplicando o instituto do crime continuado, pois se vislumbra um elemento ideal de continuidade entre as ações.

Assim, não deve ser **provido, no ponto, o recurso da acusação**.

[6] Brandão, Cláudio. Curso de Direito Penal: parte geral. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 400, 402
[7] Santos, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 2ª ed., Curitiba: ICPC, Lumen Juris, 2007, pp. 415/417

Em conclusão, deve ser <u>provido em parte</u> a apelação da acusação, para aumentar a pena-base dos crimes, em razão da valoração negativa da culpabilidade

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** se manifesta pelo seguinte:

a) **provimento em parte da apelação da defesa**, para **afastar a fixação de indenização mínima, mantendo-se a pena de confisco.**

b) **provimento em parte da apelação da acusação**, para considerar negativa a culpabilidade do réu.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2018.

LUIZ FELIPE HOFFMANN SANZI

Procurador Regional da República

Documento eletrônico assinado digitalmente por LUIZ FELIPE HOFFMANN SANZI
Procurador Regional da República da 4ª Região
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.mp.br
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS